ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024

LICENCE EN DROIT – 2e NIVEAU

GROUPE DE COURS N° II

DROIT ADMINISTRATIF

Cours de **M. Coulibaly**
Professeur agrégé des universités

►Le service public

► Version « *dense* » (facultative) :
mercredi 4 octobre 2023

www.lex-publica.com

Conseil

👍 Écoute ou **lecture préparatoire à la séance en amphithéâtre**

Avant de vous rendre à quelque séance que ce soit du cours en amphithéâtre, assurez-vous que vous n'avez pas oublié l'impératif catégorique suivant :

- ✓ **Vous devrez avoir <u>écouté</u> ou <u>lu</u>, ne serait-ce qu'en diagonale, à domicile ou ailleurs, les parties du cours indiquées par le professeur à la fin de la séance précédente.**

Concrètement, au terme de chaque séance en amphithéâtre, le professeur vous dira et vous montrera :

> « **Pour la prochaine séance, vous écouterez ou vous lirez les pages** n° x **à** n° y **du cours.** »

.

***

Partie I

Titre I

Chapitre I

▸Section I

Le service public

Nota bene :

1. Ne pas s'attarder sur les rubriques intitulées « ***Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions*** ». Elles ne feront l'objet ni d'un cas pratique, ni d'un commentaire d'arrêt, encore moins d'une question d'épreuve orale. Nécessaires à la formation, elles sont toutefois exclues des révisions en vue des différents examens – pour des raisons d'opportunité. Elles sont faciles à reconnaître : présentées en caractères plus petits, elles débutent par le sous-titre « Développements additionnels, etc. » [DÉBUT] et se terminent par [/FIN] et des astérisques (***).
2. *Ne pas chercher à retenir par cœur les exemples et les citations de jurisprudence.* Il s'agit de simples illustrations ! **Les arrêts et les définitions à retenir vous seront indiqués avant l'examen**.
3. **En principe, un clic sur un arrêt, un texte ou un schéma vous permet d'accéder directement à cet élément sur www.legifrance.gouv.frou sur** www.lex-publica.com. 🖱

Sommaire

(*interactif à l'écran*)

PREMIÈRE PARTIE : L'ENCADREMENT NORMATIF DE L'ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE 5
TITRE I : Les modalités de l'action administrative 8
CHAPITRE I : Les fonctions sociales de l'administration 9
SECTION I - La fonction de prestation : le service public 10
I - L'identification du service public 11
A - Les définitions synthétiques du service public 12
1 - Service public, service universel, service d'intérêt général et service d'intérêt économique général 13
2 - Service public et régime exorbitant 13
3 - Service public effectif et service public virtuel 13
4 - Service public et attributions naturelles de l'État 14
B - Les critères analytiques du service public 17
1 - Le caractère d'intérêt général de l'activité 19
2 - Le lien avec une personne publique 22
a - Le lien direct avec une personne publique 24
b - Le lien indirect avec une personne publique 26
i – La distinction entre les contrats de concession de service public et les marchés de service public 28
ii – Définition des contrats de concession de service public et des contrats de délégation de service public 29
iii – Définition des marchés de service public 32
iv – La problématique des redevances 36
II - Le régime du service public 38
A - La *summa divisio* : S.P.A. ou S.P.I.C. 40
1 – Le caractère exhaustif de la distinction 41
2 – L'intérêt de la distinction 42
3 – Les critères de la distinction 44
B - Les lois du service public 50
1 - Le principe de continuité 51
2 - Le principe d'adaptation ou de mutabilité 53
3 - Le principe d'égalité 55
a - La portée du principe 55
b - Les corollaires du principe 60
i - L'égal accès aux emplois publics 60
ii - La neutralité et la laïcité 62

ANNEXES (schémas) i
Ce qu'il faut entendre par « Personnes publiques » i
Ce qu'il faut entendre par « Personnes privées » ii
A quoi reconnaît-on un service public ? (Critère 1 + critère 2) ii
L'habilitation à gérer un service public (ou gestion déléguée au sens large) iv

PREMIÈRE PARTIE :
L'ENCADREMENT NORMATIF DE L'ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Qu'est-ce qu'une activité administrative ?
2. Peut-on opposer purement et simplement *activité administrative* et *activité gouvernementale* ?
3. Signification et raison d'être du titre *L'encadrement normatif de l'activité administrative* ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Qu'est-ce qu'une activité administrative ?

Une ***activité administrative*** est une activité soumise au contrôle du juge administratif. Cette réponse de principe souffre de nombreuses exceptions.

2. Peut-on opposer purement et simplement "activité administrative" et "activité gouvernementale" ?

On ne peut pas opposer purement et simplement ***activité administrative*** et ***activité gouvernementale,*** et ce, pour les raisons qui seront présentées ci-dessous.

3. Signification et raison d'être du titre "L'encadrement normatif de l'activité administrative" ?

L'encadrement normatif de l'activité administrative signifie que l'activité administrative est soumise à des règles. Pourquoi de telles règles ? Parce que, lorsqu'elle exerce ses activités, l'administration peut utiliser des moyens exorbitants du droit commun. Les règles en question permettent d'éviter

- que ces moyens soient utilisés à des fins étrangères à l'intérêt général
- ou que l'administration porte anormalement atteinte aux droits des citoyens.

↓ Développement ↓

Activité administrative et activité gouvernementale : la distinction

► L'activité administrative est souvent définie en opposition avec l'activité gouvernementale.

➢ Par exemple, Hauriou souligne[1] :

> « La fonction administrative consiste essentiellement à faire les affaires courantes du public. La fonction gouvernementale consiste à résoudre les affaires exceptionnelles qui intéressent l'unité politique, et à veiller aux grands intérêts nationaux. »

➢ Une telle définition peut se réclamer d'une intuition première : à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des autorités, les affaires traitées cèdent en quantité et en diversité ce qu'elles gagnent en abstraction et en importance.

➢ À l'appui de cette intuition, **deux observations :**

1. Numériquement, les administrateurs l'emportent de beaucoup sur les gouvernants,

2. Juridiquement, la Constitution subordonne les administrateurs aux gouvernants. En effet, elle dispose, en son article 20 :

> « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
> Il ***dispose de l'administration*** et de la force armée. »

La subordination, un critère parfois inopérant

➢ Mais cette dernière observation n'emporte guère l'adhésion, et ce pour deux raisons :

1. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, notamment en prenant des actes…administratifs. La dichotomie Gouvernement - administration est donc parfois inopérante, puisqu'au sommet de l'État les mêmes personnes gouvernent et administrent à la fois. La subordination de l'administration au Gouvernement perd de son sens.

2. Le Parlement et les différentes juridictions sont également le siège d'une activité administrative accessoire, dont, naturellement le Gouvernement ne dispose pas au sens susmentionné. À nouveau, on peut soutenir que l'administration n'est pas toujours **subordonnée** au Gouvernement.

Au demeurant, étymologiquement, les mots *administration* et *ministre* ont la même racine latine : *ministrare*, qui signifie servir.

Le contrôle du juge administratif, un critère souvent opérant

► Comment distinguer la fonction administrative de la fonction gouvernementale si le critère de la subordination de la première à la seconde perd souvent toute pertinence ?

Peut-être en troquant cette opposition stérile contre une distinction a priori féconde.

➢ Nous nous évertuerons

1. d'abord, à caractériser d'une manière intrinsèque l'administration,

2. ensuite, à la distinguer, non du seul gouvernement, mais de toutes les autres activités étatiques majeures.

➢ Nous serons alors à même de relever

1. que l'activité administrative est soumise au contrôle du **juge** administratif,

2. que les activités non administratives échappent à ce contrôle.

---

[1] *Précis élémentaire de Droit administratif*, p. 10, 1938.

► **Le critère juridique du caractère administratif d'une activité, ce serait donc le contrôle exercé sur cette activité par le juge administratif**. Si ce critère se vérifie plus souvent que le précédent (la subordination), il n'est pas exempt de toute faiblesse :

1. Certaines activités dites administratives échappent au contrôle du juge administratif ;

2. On ne saurait pas toujours dire avec précision quand une activité relève de ce contrôle.

► Néanmoins, en pratique, le critère du contrôle exercé par le juge administratif est souvent retenu car

1. les exceptions ne ruinent *pas nécessairement* le principe (*Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis* – voir Lexique sur www.lex-publica.com),

2. l'imprécision est une invitation au pragmatisme dans un domaine que l'on considère comme étant rebelle à toute systématisation.

Explication et justification des Titre I et II de la Partie I du cours

► L'activité administrative est le fait de personnes, d'organes dotés d'une autorité dite spéciale ou générale. Elle s'identifie parfois avec l'utilisation effective de cette autorité. Elle donne également lieu à l'exercice de *prérogatives exorbitantes du droit commun*. En effet, les organes administratifs disposent de moyens dont sont dépourvus les simples particuliers. En raison de leur nature juridique ou matérielle, ces moyens sont susceptibles de porter atteinte aux libertés publiques et individuelles. C'est la raison pour laquelle leur usage doit être juridiquement réglementé. Et il l'est, en grande partie, par le droit administratif.

D'une manière générale, c'est l'activité administrative elle-même qui se trouve encadrée par des règles, des normes. Cette situation manifeste l'existence d'un **État de droit**. Au contraire de l'**État de police** ou d'arbitraire, l'État de droit se caractérise par la soumission effective des pouvoirs publics à des normes extérieures.

- Quel est le contenu de l'activité administrative ? (Titre **I**)
- Quel est le contenu des normes qui encadrent l'activité administrative ? (Titre **II**)

*

➲ **Rappel** : *Ne pas chercher à retenir par cœur les exemples et les citations de jurisprudence.* Il s'agit de simples illustrations ! **Les arrêts et les définitions à retenir vous seront indiqués avant l'examen**.

*

TITRE I : Les modalités de l'action administrative

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. De quelles fonctions ou missions l'administration est-elle chargée ?
2. Quels moyens l'administration utilise-t-elle pour mener à bien ses missions ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. De quelles fonctions ou missions l'administration est-elle chargée ?

L'administration a en charge plusieurs fonctions ou missions. Les plus importantes d'entre elles sont le ***service public*** et la ***police administrative*** (Chapitre **I**).

2. Quels moyens l'administration utilise-t-elle pour mener à bien ses missions ?

Pour mener à bien ses missions, l'administration utilise des moyens *juridiques* et des moyens *matériels*. Les moyens juridiques, qui seuls importent dans un cours de droit, sont, pour l'essentiel, d'une part, des ***actes administratifs***, c'est-à-dire des actes administratifs unilatéraux et des contrats administratifs (Chapitre **II**), et, d'autre part, des ***actes de droit privé*** (contrats de droit privé…)

↓ Développement ↓

CHAPITRE I : Les fonctions sociales de l'administration

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Que faut-il entendre par *fonctions sociales* de l'administration ?
2. Peut-on opposer purement et simplement les deux fonctions sociales majeures de l'administration ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Que faut-il entendre par "fonctions sociales" de l'administration ?

Par ***fonctions sociales*** de l'administration, il faut entendre les tâches ou les missions que l'administration accomplit au bénéfice de la collectivité et dont les plus importantes sont le ***service public*** et la ***police administrative***.

2. Peut-on opposer purement et simplement les deux fonctions sociales majeures de l'administration ?

On ne peut pas opposer purement et simplement ces deux fonctions sociales majeures de l'administration car elles sont étroitement ***liées***.

↓ Développement ↓

Fonction de prestation et fonction normative, une distinction classique

Selon Charles Eisenmann, l'administration remplit deux fonctions sociales majeures :

1. **Une fonction de prestation :** elle consiste à fournir aux administrés des prestations, c'est-à-dire des biens et des services - distribution d'eau, d'électricité, de gaz, enseignement, enlèvement et traitement des ordures ménagères… Bref à rendre service. L'expression « fonction de prestation » caractérise l'activité de *service public* ;
2. **Une fonction normative :** elle consiste à édicter des règles, des normes. Ces règles déterminent ce que doit être le comportement des administrés : obligation de porter un masque, limitation de vitesse, interdiction de projeter un film ou d'organiser une manifestation… L'expression « fonction normative » caractérise l'activité de *police administrative.*

Fonction de prestation et fonction normative, une distinction relative

La distinction de Charles Eisenmann a le mérite de la clarté. Mais elle pêche par son manichéisme conceptuel. **Les deux fonctions sont, en fait, étroitement liées**.

La fonction de prestation est remplie dans le cadre d'une réglementation.

Exemple : les universités. Les usagers y bénéficient de prestations - enseignement, évidemment - tout en étant tenus au respect de certaines règles - pas toujours écrites d'ailleurs.

Inversement, la fonction normative n'exclut pas la fourniture de prestations. La police administrative apparaît aussi comme un service public.

On ne peut retenir qu'une version revue et corrigée de la distinction : **certaines activités administratives sont principalement des activités de prestation, d'autres principalement des activités normatives.**

SECTION I - La fonction de prestation : le service public

L'importance juridique de la notion de service public

► Le service public constitue une **donnée fondamentale du droit administratif** pour trois raisons :

1. Le service public permet de **définir** un grand nombre de notions essentielles du droit administratif : contrat administratif, agent public, domaine public, expropriation pour cause d'utilité publique…

2. Le service public sert souvent de **critère** à l'application du droit administratif et à la compétence du juge administratif. Certains auteurs avaient même ambitionné d'en faire *le Critère* - *Cf. Introduction générale*.

3. Dès lors qu'une activité est reconnue comme un service public, elle est soumise à des **règles spécifiques** (notamment, aux **lois du service public**).

Pourtant, en dépit de son rôle central, le service public pose problème.

Didier Truchet remarque :

> « Personne n'a jamais réussi à donner du service public une définition incontestable : le législateur ne s'en est pas soucié, le juge ne l'a pas voulu, la doctrine ne l'a pas pu. »[1]

D'après l'auteur, la signification du concept varie selon les circonstances de son emploi : il est devenu un label qui recouvre des réalités juridiques variées[2]. Au contraire, le statut, le régime du service public semble échapper à toute contingence. En clair, on ne saurait pas ce qu'est un service public, mais on saurait quelles sont les règles qui lui sont applicables. Situation traumatisante pour l'intellect.

Qui plus est, Pierre Nicolaÿ, qui fut vice-président du Conseil d'État, prévient : « Ce n'est pas la modestie mais la sagesse qui commande de s'abstenir de définir le service public. »[3]

L'optimisme vient de la commissaire du gouvernement Célia Vérot : « L'identification des services publics n'est pas […] entièrement subjective, le service public n'est pas une pure étiquette » - conclusions sur CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541.

*

[1] *Nouvelles récentes d'un illustre vieillard : label de service public et statut de service public*, A.J.D.A. 1982, pp. 427-439.
[2] C'est la *théorie du label*.
[3] *Cours de droit administratif* professé à l'École nationale des Ponts et Chaussées, Éditions Eyrolles, 1976

I - L'identification du service public

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Qu'est-ce qu'un *service public* ?

2. Quel intérêt juridique y a-t-il à reconnaître une activité comme étant un service public ? Autrement dit, quelles conséquences juridiques découlent de la qualification de service public donnée à une activité ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Un ***service public*** est une activité exercée par une personne publique ou par une personne privée (avec l'habilitation et sous le contrôle d'une personne publique) en vue, principalement, de répondre à un besoin d'intérêt général.

Cette définition, dont chacun des termes compte, résulte d'une évolution jurisprudentielle exposée à la fin de ce I.

2. Lorsqu'une activité est reconnue comme étant un service public, elle est *ipso facto* soumise au **régime** du service public (Cf. **II**, p. 38). De plus, l'article 1382 du code général des impôts exonère de la **taxe foncière sur les propriétés bâties** les immeubles des collectivités publiques lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils sont non productifs de revenus[1].

↓ Développement ↓

[1] CE, 10 janvier 2005, *Ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie c. Région Île-de-France*, n° 263506. Deux conditions pour bénéficier de l'exonération :

1. Affectation de l'immeuble à un service public,

2. Absence de revenus (pour le propriétaire : CE, *6 novembre 1985, Ministre de l'agriculture*, n° 45928 ; CE, 12 mai 1997, *Ministre de l'Économie et des finances c. Commune de Mont-les-Neufchâteau*, n° 172318.)

A - Les définitions synthétiques du service public

➢ ***Synthétique*** est entendu **ici** dans son acception ***kantienne*** de « *conçu a priori » et « non à partir de l'expérience », de la réalité concrète*.

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Qu'est-ce qu'une *définition synthétique* ?
2. Pourquoi ne peut-on pas retenir les définitions synthétiques du service public ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Qu'est-ce qu'une définition synthétique ?

Une ***définition synthétique*** est une définition qui ne part pas de la réalité telle qu'elle existe, mais de la réalité telle qu'on voudrait (idéologiquement ou non) qu'elle fût.

2. Pourquoi ne peut-on pas retenir les définitions synthétiques du service public ?

On ne peut pas retenir les définitions synthétiques du service public si l'on veut décrire la réalité jurisprudentielle, car aucune de ces définitions n'est confirmée par la ***jurisprudence***.

↓ Développement ↓

► Jacques Chevallier observe : « La notion de service public est saturée de significations multiples qui se superposent, s'entrecroisent, renvoient les unes aux autres, et entre lesquelles le glissement est constant. »[1] Pour M. Chevallier, le service public correspond tout à la fois à

- une entité sociale,
- une notion juridique,
- un opérateur idéologique : « Il sculpte le mythe d'un État bienveillant, uniquement soucieux du bien-être de tous ». Selon Léon Duguit, « les gouvernants ne sont plus les organes d'une personne publique qui commande ; ils sont les gérants d'affaires de la collectivité. » Hauriou renchérit : «L'État devient une puissance au service d'une idée ». Enfin, C. Wiéner remarque : « Le droit de commander se transforme en obligation de gérer. »

► La notion de service public est une source inépuisable de controverses sémantiques et juridiques, de logomachies. Ici aussi, prendre parti, c'est, nécessairement, prendre à partie. À tout le moins, force est de procéder par élimination.

➢ **Quelles sont donc les approches à éliminer ? Qu'est-ce que le service public n'est pas ?**

[1] *Le service public*, QSJ, P.U.F 1994, p. 3

*****Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions***** [DÉBUT]

Notions voisines mais différentes de la notion de service public ▼

1 - Service public, service universel, service d'intérêt général et service d'intérêt économique général

On ne saurait confondre le concept de service public avec ces notions issues du droit [communautaire] de l'Union européenne.

► ***Services universels :*** « Services définis d'une qualité donnée, ainsi que la fourniture de ces services à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable » - Résolution du Conseil, du 7 février 1994, *sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications*.

► ***Service d'intérêt général :*** « Activité de services marchands ou non, considérée d'intérêt général par les autorités publiques, et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public ».

► ***Service d'intérêt économique général :*** « Activité de services marchands remplissant des missions d'intérêt général, et soumise de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service public. » C'est le cas en particulier des services en réseaux de transport, d'énergie, de communication…

Dans son *Livre blanc sur les services d'intérêt général* publié en 2004, la Commission européenne prévient :

« Il convient de souligner que les termes "service d'intérêt général" et "service d'intérêt économique général" ne doivent pas être confondus avec l'expression "service public", qui est moins précise.

Celle-ci peut avoir différentes significations et être ainsi source de confusion. Elle peut se rapporter au fait qu'un service est offert au grand public ou qu'un rôle particulier lui a été attribué dans l'intérêt public, ou encore se référer au régime de propriété ou au statut de l'organisme qui fournit le service en question. Elle n'est dès lors pas utilisée dans le Livre blanc. »

Mutatis mutandis, cette mise en garde vaut aussi pour la notion de service universel.

➢ On comprend mieux que dans son rapport public pour 1994, le Conseil d'État ait souligné : « L'Europe n'instruit pas le procès du ou des service (s) public(s) ; elle fait pire : elle ignore largement la notion de service public et l'existence de services publics. »

2 - Service public et régime exorbitant

On reconnaîtrait un service public au fait qu'il est soumis à un **régime exorbitant**, c'est-à-dire au **droit administratif**. Thèse inacceptable. Il est constant que certains services publics sont globalement soumis au droit privé. Ils n'en restent pas moins des services publics : les lois du service public leur sont applicables. Parfois, le Conseil d'État admet qu'une personne privée gère un service public malgré l'absence de prérogatives de puissance publique : CE, 20 juillet 1990, *Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs*, n°s 69867 et 72160 ; CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541 (voir plus loin). **En fait, l'approche examinée ici confond indices et conséquences éventuelles d'un statut.**

3 - Service public effectif et service public virtuel

À côté des services publics reconnus (services publics effectifs) il y aurait des services publics en puissance - services publics virtuels. C'est la thèse qui a été soutenue naguère – Voir, par exemple, B. Chenot, conclusions sur CE, 6 février 1948, *Radio-Atlantique* (Rec. 65, RDP 1948.244, concl. Chenot, note Jèze) ; voir aussi CE, Sect., 5 mai 1944, *Compagnie maritime de l'Afrique orientale*, n° 66679.

Cette théorie se présente ainsi :

▪ Une activité gérée par une personne privée revêt un caractère d'intérêt général marqué.

▪ Elle ne deviendra un service public qu'à partir du moment où l'administration la soumettra à une réglementation comportant des obligations de service public.

▪ Jusqu'à l'intervention de cette réglementation, l'activité en question restera un service public virtuel.

La théorie du service public virtuelle plaçait les personnes privées dans une situation d'incertitude quant au régime juridique ultérieur d'une activité qu'elles choisissent a priori d'assurer sur un marché. On a pu soutenir qu'elle débouchait sur une gestion par inadvertance du service public. Critiquée par la doctrine, elle est restée sans lendemain jurisprudentiel.

Sans aller jusqu'à faire revivre la théorie du service public virtuel, le Conseil d'État a admis, dans un avis en date du 18 mai 2004 relatif à la Cinémathèque française (association soumise à la loi du 1er juillet 1901), l'idée d'un service public créé spontanément par une personne privée et reconnu a posteriori par une personne publique - CE, Sect., 18 mai 2004, Avis n° 370.169 ; EDCE 2005, p. 185[1].

4 - Service public et attributions naturelles de l'État

Selon certains auteurs, le service public correspond à une donnée objective. Il suffit d'en constater l'existence. Et cette constatation se fonde sur la *nature* même de l'activité exercée. Il existe des tâches constituant *objectivement* des services publics, un *domaine naturel* du service public. C'est la thèse du *service public par nature*. Dans ses conclusions sur TC, 22 janvier 1921, *Colonie de la Côte d'Ivoire c. Société commerciale de l'Ouest africain*, n° 00706 – « Arrêt du ***bac d'Eloka »*** - le commissaire du gouvernement Matter rend compte de cette thèse : « Il faut entendre par "service public" une organisation gérée par un organe de l'administration publique en vue de l'accomplissement de la fonction administrative de l'État. Ainsi ne seront services publics que ceux organisés par l'État ou l'un de ses démembrements en vue d'accomplir un acte normal de sa fonction, pour atteindre son but naturel. […] Certains services sont de la nature, de l'essence même de l'État ou de l'administration publique. »

Quelle valeur juridique peut-on accorder à cette approche du service public ?

En 1997, le Conseil d'État a utilisé l'expression « service public par nature » lorsqu'il a statué sur un recours dirigé contre un décret relatif aux bases de données juridiques - essentiellement Legifrance :

« Considérant que ***la mise à disposition et la diffusion de textes, décisions et documents juridiques*** de la nature de ceux mentionnés à l'article 1er, précité, du décret attaqué, dans des conditions adaptées à l'état des techniques, s'appliquant, sans exclusive ni distinction, à l'ensemble de ces textes, décisions et documents - et notamment de ceux dont la diffusion ne serait pas économiquement viable - et répondant aux exigences d'égalité d'accès, de neutralité et d'objectivité découlant du caractère de ces textes**, *constituent, par nature, une mission de service public*** au bon accomplissement de laquelle il appartient à l'État de veiller ; » - CE, 17 décembre 1997, *Ordre des avocats à la Cour de Paris*, n° 181611.

Toutefois, il serait déraisonnable d'énoncer une règle générale à partir de cette référence au service public par nature :

- d'une part, parce que dans l'espèce précitée, le décret lui-même avait qualifié les bases de données en question de service public, même si cette qualification, donnée par voie réglementaire, ne lie pas le juge,
- d'autre part, parce que le **domaine du service public est essentiellement contingent** ; le juge a reconnu le caractère de services publics à des activités auxquelles il l'avait naguère ou jadis refusé, et inversement.

  ✓ ***Exemple*** : En 1906 (CE, 5 décembre 1906, *Ville de Lyon*, Rec. 892), puis en 1916 (CE, 7 avril 1916, *Astruc et Société du théâtre des Champs-Élysées,* Rec. p. 163), le Conseil d'État estime que l'exploitation d'un théâtre n'est pas un service public :).

[1] « Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les missions en cause sont constitutives d'un service public culturel, nonobstant le fait que la Cinémathèque soit née d'une initiative privée. […]
La mission exercée par la Cinémathèque ne correspond donc pas à une dévolution de la part de la puissance publique d'un service public. Elle s'analyse en la reconnaissance par l'État du caractère d'intérêt général de l'action menée par l'association, assortie d'un droit de regard étendu sur ses activités et d'une contribution financière importante accordée annuellement par le canal du CNC. » - CE, Sect., 18 mai 2004, Avis n° 370.169 ; EDCE 2005, p. 185

Le doyen Hauriou applaudit avec enthousiasme - avec…passion :

« On peut poser en principe que les services publics doivent être des entreprises complètement bonnes et utiles pour la vie sociale, à moins qu'elles ne soient tellement nécessaires que cette nécessité même fasse passer par-dessus leurs inconvénients […]

En somme, si l'on étudiait la question dans son ensemble et d'un point de vue historique, on constaterait que, par un lent progrès, les États s'efforcent d'épurer leurs services publics au point de vue de la moralité, même lorsqu'ils constituent des monopoles financiers. Alors, ce ne serait peut-être pas le moment d'ériger en services publics les entreprises de spectacle et de théâtre, qui ne présentent aucune nécessité, même financière, dont l'inconvénient majeur est d'exalter l'imagination, d'habituer les esprits à une vie factice et fictive, au grand détriment de la vie sérieuse, et d'exciter les passions de l'amour, lesquelles sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l'intempérance. Il est déjà très discutable que les administrations publiques subventionnent des entreprises de cette nature, et certes il vaudrait mieux s'orienter vers la suppression des subventions que vers l'érection en services publics. »[1]

Mais sept ans plus tard, coup de théâtre : le Conseil d'État se ravise - CE, 27 juillet 1923, *Gheusi*.

► **Le domaine du service public varie donc selon les époques et l'idéologie des gouvernants.**

Exemples : Ont été reconnus comme des activités de service public

* Un festival de bande dessinée - CE, 25 mars 1988, *Commune d'Hyères*, n° 61257,

* Les feux d'artifice organisés par les communes le 14 Juillet - CE, Sect., 14 novembre, 1948, *Jacquin*,

* Un lâcher de taureaux organisé au cours de la fête traditionnelle de l'Abrivado dans les rues de Saint-Rémy-de-Provence - TC, 22 avril 1985, *M. Laurent c. Comité des fêtes de la commune de Saint-Rémy-de-Provence*, n° 02368.

[/FIN]

***

Piste à suivre pour définir la notion de service public

► En conséquence de ce qui précède, nous nous évertuerons à donner du service public une définition

- qui mêle données objectives et données subjectives
- et qui transcende les contingences en révélant les invariants. Autrement dit, une définition qui révèle ce qui ne change pas, **une définition qui vaille à la fois pour un service public de 1900 et pour un service public de 2021**.

► D'un strict point de vue logique, *le service public donne parfois lieu à deux sortes de définitions* :

1. Une définition purement organique ou formelle : le service public, c'est toute activité exercée par une *personne publique*, un *organisme* public. **Objection :** selon la jurisprudence, toutes les activités exercées par des personnes publiques ne sont pas des services publics ; et certaines personnes privées ont en charge des services publics. **Une définition purement organique ou formelle n'est donc pas recevable ; elle est contredite par la jurisprudence** ;

2. Une définition purement fonctionnelle ou matérielle : le service public, c'est toute *activité d'intérêt général*. **Objection :** la jurisprudence ne considère pas toutes les activités d'intérêt général comme étant des services publics. **Une définition purement fonctionnelle ou matérielle n'est donc pas acceptable ; elle est infirmée par la jurisprudence**.

► En fait, chacune des définitions précédentes éclaire un seul aspect du concept de service public.

---

[1] Note sous CE, 7 avril 1916, *Astruc* in *La jurisprudence administrative de 1892 à* 1929, Librairie du Recueil Sirey, 1929 (Nouveau tirage 1931), T. I, p. 332 et s.

► Par conséquent, « **nous retiendrons ici une définition organico-fonctionnelle** ou **organico-matérielle du service public.**

➢ Une telle définition fait une large place à l'intention des pouvoirs publics. Ceux-ci ont en charge le bien commun.

Par suite, la question « Telle activité constitue-t-elle un service public ? » implique la question « Les pouvoirs publics ont-ils eu *l'intention* d'en faire un service public ? »

► Dans certains cas, la volonté subjective des pouvoirs publics est patente.

➢ Il s'agit essentiellement « des **cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public** » - CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541.

➢ Confronté à de tels cas, le juge se borne à prendre acte de la volonté du législateur. **Il considérera comme un service public ce que le législateur a qualifié comme tel, et il ne considérera pas comme un service public ce à quoi le législateur a refusé la qualification de service public.**

► En l'absence d'une volonté législative, le juge retiendra ou refusera la qualification de service public en se fondant sur des **indices** (des **critères** ou des **conditions**).

➢ Quels sont les indices ou critères du service public ? À quoi reconnaît-on un service public ?

➢ Quelles sont les conditions qu'une activité doit remplir pour pouvoir recevoir la qualification de service public ?

Importance de l'arrêt CE, Sect., 22 février 2007, A.P.R.E.I. pour la définition du service public

► **Les critères du service public sont *partiellement* résumés sous la forme d'un faisceau d'indices** (intérêt général, habilitation, prérogatives de puissance publique et contrôle) **dans ce considérant du Conseil d'État :**

« [U]ne personne privée qui assure ***une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration*** et qui est dotée à cette fin de ***prérogatives de puissance publique*** est chargée de l'exécution d'un ***service public*** ; que, ***même en l'absence de telles prérogatives***, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour ***vérifier*** que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission […] » - CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541[1].

➢ On aura relevé que, selon le Conseil d'État, la détention de prérogatives de puissance publique par la personne privée n'est pas une condition *sine qua non* en vue de la qualification de service public.

Si nous ne redoutions pas les complications inutiles, nous pourrions reformuler notre définition en y incluant les prérogatives de puissance publique.

❖ **Définition inutilement compliquée :** Un ***service public*** est une activité exercée par une personne publique ou par une personne privée dotée ou non de prérogatives de puissance publique (avec l'habilitation et sous le contrôle d'une personne publique) en vue, principalement, de répondre à un besoin d'intérêt général.

La détention de prérogatives de puissance publique par la personne privée n'étant pas une condition nécessaire, nous revenons finalement à notre définition de départ.

[1] Cf. aussi CE, 25 juillet 2008, *Commissariat à l'Énergie Atomique*, n° 280162 et 280163.

❖ **Définition retenue dans ce cours :** Un ***service public*** est une activité exercée par une personne publique ou par une personne privée (avec l'habilitation et sous le contrôle d'une personne publique) en vue, principalement, de répondre à un besoin d'intérêt général.

B - Les critères analytiques du service public

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Que signifie l'expression *Les critères analytiques du service public* ?
2. Quels sont les critères qui permettent de conclure à l'existence d'un service public ?
3. Une activité peut-elle remplir tous ces critères sans être considérée comme un service public ?
4. Quelle doit être ma démarche lorsque l'on me demande si une activité X constitue ou non un service public ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Que signifie l'expression "Les critères analytiques du service public" ?

L'expression ***Les critères analytiques du service public*** désigne les indices (ou le faisceau d'indices) qui permettent de conclure qu'une activité donnée est un service public.

2. Quels sont les critères qui permettent de conclure à l'existence d'un service public ?

Il s'agit des ***deux*** critères retenus par le juge : **critère matériel** et **critère organique**.

Pour qu'une activité soit considérée comme un service public, elle doit satisfaire aux deux critères suivants :

a. caractère d'**intérêt général** (*critère matériel*): la satisfaction d'un besoin d'intérêt général doit constituer la raison d'être de cette activité ;
b. lien direct ou indirect avec une **personne publique** (*critère organique*).

Quant à la détention, par une personne privée, de ***prérogatives de puissance publique***, **elle n'est plus considérée comme nécessaire** à la qualification générique de service public.

CE, 20 juillet 1990, *Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs c/ Vivien*, n°s 69867 et 72160 ;

CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541 :

« [U]ne personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, ***même en l'absence de telles prérogatives***, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission […] »

En fait, la détention de ***prérogatives de puissance publique*** est une conséquence possible de l'existence d'un service public. Il s'agit aussi d'un indice permettant parfois de conclure à la qualification d'acte administratif - CE, Sect., 13 octobre 1978, *ADASEA du Rhône*, n° 03335.

3. Une activité peut-elle remplir tous ces critères sans être considérée comme un service public ?

Une activité peut remplir ces deux critères - intérêt général et lien avec une personne publique - sans être considérée comme un service public. Par exemple, la gestion du domaine privé d'une personne publique n'est jamais considérée comme une activité de service public.

Les deux critères (matériel et organique) constituent donc

a. des conditions nécessaires (ces critères sont toujours exigés),

b. des conditions presque toujours suffisantes (il existe des exceptions, voir ci-dessus)

pour qu'une activité soit considérée comme une activité de service public.

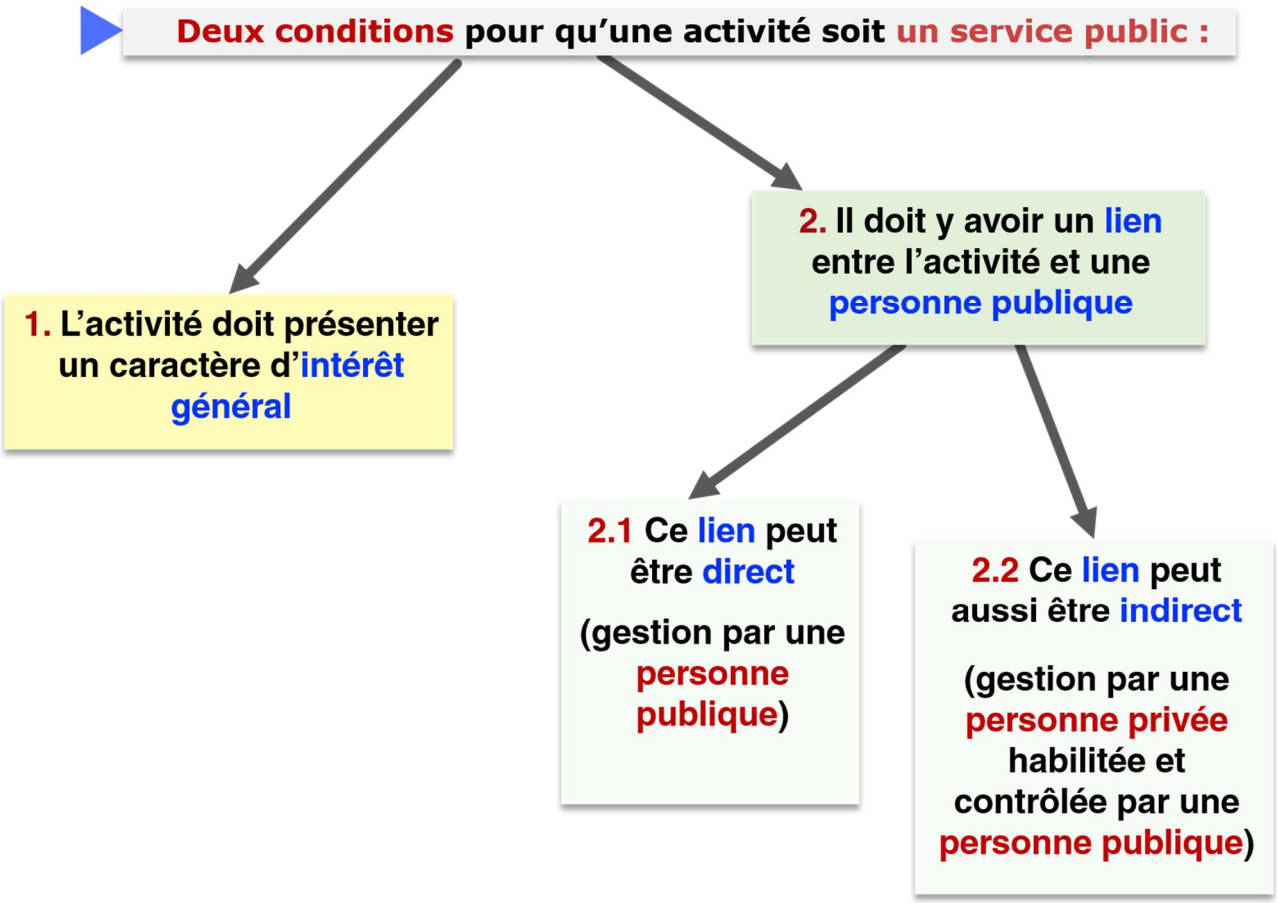
4. Quelle doit être ma démarche lorsque l'on me demande si une activité X constitue ou non un service public ?

Si l'on me pose une telle question, ma démarche sera la suivante :

Étape n° 1. Je me demande si la loi a qualifié de service public cette activité X ou si elle a exclu que ladite activité soit un service public. Dans l'affirmative, ma tâche est terminée, je ne passerai pas à l'étape n° 2 : je dirai, comme le ferait le juge, que l'activité X en question est un service public (qualification accordée par la loi) ou n'est pas un service public (qualification exclue par la loi). Dans la négative, donc en l'absence aussi bien d'octroi que d'exclusion de la qualification de service public de la part du législateur, je passerai à l'étape n° 2 qui suit.

Étape n° 2. Je me demande si l'activité X en cause remplit les critères jurisprudentiels requis pour la qualification de service public. Selon que la réponse à cette dernière question sera positive ou négative, je conclurai que j'ai affaire ou non à un service public.

↓ **Développement** ↓



1 - Le caractère d'intérêt général de l'activité

❖ C'est le *critère matériel*.

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Question initiale :

► Qu'est-ce que *l'intérêt général,* premier élément constitutif du service public ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. L'intérêt général n'est jamais l'intérêt de tout le monde ;
2. L'intérêt général, c'est souvent l'intérêt de la majorité ;
3. L'intérêt général, c'est parfois l'intérêt d'une minorité ;
4. L'intérêt général, c'est toujours l'intérêt de certains.

↓ Développement ↓

► Tardieu, dans ses conclusions sur CE, 7 août 1909, *Winkell* et *Rosier*, n° 37317 (Deux espèces), souligne : « Quand l'État, les départements ou les communes se substituent à la libre initiative des particuliers pour organiser un **service public**, c'est le plus souvent afin de **procurer à tous les habitants de la France, sur les points les plus reculés du territoire, la satisfaction de besoins généraux auxquels l'initiative privée ne pourrait assurer qu'une satisfaction incomplète et intermittente**. »

L'intérêt général : ce qu'il est et ce qu'il n'est pas

► **La définition de l'intérêt général n'est pas aisée** - comme du reste celle d'autres concepts majeurs du droit administratif. Jacques-Henri Stahl remarque : « L'intérêt général est une notion d'une certaine plasticité, volontairement imprécise, qui permet au juge d'adapter les contours de sa jurisprudence aux aspirations ou aux nécessités de son temps. » [1]

► On relève tout de même deux certitudes :

1. L'intérêt général - ou public - ne s'oppose pas nécessairement à l'intérêt particulier ou privé. Par exemple, l'activité des théâtres municipaux sert, peut-être un intérêt public. Cependant, elle sert aussi et surtout l'intérêt particulier des amateurs de théâtre - qui ne sont pourtant pas légion ;

2. L'intérêt général n'est pas une simple somme d'intérêts particuliers. Par exemple, dans certains cas, il y aurait quelque paradoxe à vouloir additionner l'intérêt particulier des chauffards et celui des victimes d'accidents de la route, l'intérêt particulier des bouilleurs de cru (fabricants d'alcool) et celui des victimes de l'alcoolisme - ou de leurs…conjoints.

► La combinaison de ces deux certitudes autorise une certaine approximation de la notion d'intérêt général. L'intérêt général coïncide nécessairement avec les intérêts des administrés, donc avec des intérêts particuliers. Mais pas avec tous les intérêts particuliers. En effet, ceux-ci sont souvent contradictoires ou contraires.

► Par conséquent, **l'intérêt général est souvent le résultat d'un arbitrage entre différents intérêts particuliers**.

➢ L'arbitrage a lieu :

1. soit sur le fondement d'un **critère quantitatif** : l'intérêt du plus grand nombre - éventuellement revu et corrigé par les gouvernants ;

2. soit sur le fondement d'un **critère qualitatif** : sur des valeurs. Par exemple, les chômeurs ne sont pas majoritaires. Mais cette vérité n'empêche pas que leurs intérêts particuliers l'emportent, dans certains cas, sur ceux de la majorité - services publics gratuits aux frais de la majorité. La survie d'une minorité est jugée ici plus importante que certains intérêts pécuniaires de la majorité.

► *Mais l'intérêt général singularise-t-il réellement l'activité de service public ?*

➢ Deux objections pourraient en faire douter :

1. On sait que l'intérêt général gouverne toutes les activités publiques. L'administration ne doit agir que dans un but d'intérêt général – Cf. *Introduction générale*. Par suite, toutes les activités administratives servent, en principe, l'intérêt général. Et pourtant, toutes les activités administratives ne sont pas des services publics ;

2. De surcroît, il existe des entreprises privées qui sont d'intérêt général, sans être des services publics.

✓ ***Exemple*** : la première chaîne de télévision prétend, elle aussi, être au service du public.

➢ Ces deux objections n'ont aucune pertinence dirimante. *En réalité, ce qui singularise le service public, c'est le fait que la satisfaction d'un besoin d'intérêt général constitue le but de sa création, sa raison d'être.*

---

[1] Conclusions sur : CE, Sect., 29 décembre 1997, *Commune de Nanterre*, n° 157500 ; CE, Sect., 29 décembre 1997, *Commune de Gennevilliers*, n° 157425, (RFDA 1998 p. 539).

Pour la qualification de service, le caractère d'intérêt général de l'activité est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut y ajouter le lien avec une personne publique.

**

2 - Le lien avec une personne publique[1]

❖ C'est le *critère organique*.

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Une activité d'intérêt général est-elle nécessairement un service public ?
2. Que faut-il entendre par la formule *lien avec une personne publique* ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Une activité d'intérêt général est-elle nécessairement un service public ?

Une activité d'intérêt général ne peut être considérée comme un service public que s'il existe un certain type de lien entre cette activité et une personne publique.

2. Que faut-il entendre par la formule "lien avec une personne publique" ?

Par la formule ***lien avec une personne publique***, on entend ***l'une des deux*** situations suivantes :

a. Ou bien l'activité d'intérêt général est gérée directement par une personne publique (***lien direct*** avec une personne publique) ;

b. Ou bien l'activité d'intérêt général est gérée par une personne privée avec l'habilitation et sous le contrôle d'une personne publique (***lien indirect*** avec une personne publique)

➢ **Principe du libre choix du mode de gestion :** sauf dispositions législatives ou principes jurisprudentiels contraires[2], les personnes publiques ont la liberté de choisir le mode de gestion du service public dont elles ont la responsabilité[3].

↓ Développement ↓

[1] Présence d'une personne publique, comme dans le contrat administratif.

[2] Exemple : certains services publics ne peuvent en principe être délégués à des personnes privées. Tel est le cas de la police - (CE, Ass., 17 juin 1932, *Ville de Castelnaudary*, p. 595, D 1932.3.26, concl. Josse ; CE, Sect., 28 mai 1958, Consorts *Amoudruz*, Rec. 301, AJDA 1958.309, chr. ; CE, 23 octobre 1974, *Valet*, Rec. 500, AJDA 1975.363, note Vier). Voir, SECTION II, cours sur la police administrative.

[3] CE, 4 mai 1906, *Babin*, Rec. 363, concl. Romieu ; CE, 18 mars 1988, *Loupias*, n° 57893.

Personnes publiques (raccourci désignant les personnes morales de droit public)

L'État

Les personnes publiques à compétence spéciale

Exemples :

- les **établissements publics** : **universités**…
- les **groupements d'intérêt public**
- **la Banque de France** (personne publique à part)

Les collectivités territoriales

Exemples :

- les **communes**
- les **départements**
- les **régions**…

*

Exemples de personnes privées

Personnes physiques

Les particuliers : Vous, moi, votre voisin, etc.

Personnes morales de droit privé appartenant à des particuliers

- Entreprises privées, sociétés privées,
- associations, etc.

Personnes morales de droit privé appartenant à des personnes morales de droit public

- Entreprises publiques…

Exemple : **E.D.F.** (Société Anonyme à Conseil d'administration depuis la loi du 9 août 2004) « appartient » à l'**État** (**83,7%** du capital en juin 2019)

a - Le lien direct avec une personne publique

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Question initiale :

► Que signifie l'expression *lien direct avec une personne publique* ?

Réponse soutenue et développée dans ce cours :

➢ L'expression ***lien direct avec une personne publique*** sert à désigner ***l'une des deux*** situations suivantes :

1. ou bien la personne publique juridiquement responsable d'une activité d'intérêt général déterminée ***gère elle-même*** cette activité d'intérêt général (*gestion en régie*) ;

2. ou bien la personne publique juridiquement responsable d'une activité d'intérêt général ***a confié la gestion*** de cette activité d'intérêt général à une ***autre personne publique***.

Dans les deux cas, c'est une personne publique qui gère l'activité d'où le recours à l'expression *lien direct avec une personne publique* pour désigner ces deux situations.

↓ Développement ↓

Une personne publique - État, collectivité territoriale…- gère directement une activité d'intérêt général avec ses propres moyens humains et matériels - gestion directe.

Lien direct avec une personne publique : deux formes de lien et de gestion

► Il y a lieu de distinguer deux formes de gestion par une personne publique, deux formes de lien direct entre une personne publique et une activité d'intérêt général :

1. la **gestion directe par la personne publique même qui est juridiquement responsable** de l'activité générale en question et

2. la **gestion par une autre personne publique**, **qui n'est pas juridiquement responsable** de l'activité général en question.

Gestion directe par la personne publique juridiquement responsable

1. La gestion directe par la personne publique même qui est juridiquement responsable de l'activité générale en question peut prendre trois formes :

a. **gestion par une régie simple** (c'est-à-dire par les propres services de la personne publique),
b. **gestion par une régie** (c'est-à-dire par un service de la personne publique) à laquelle la personne publique a accordé une **autonomie financière** ou une **personnalité juridique propre,**
c. **gestion par un organisme créé par la personne publique et assimilé aux services de cette personne publique** (personne privée transparente).

✓ **Exemple** : CE, Sect., 6 avril 2007, *Commune d'Aix-en-Provence*, n° 284736 :
« Considérant que, lorsqu'elles sont **responsables** d'un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d'en **assurer directement la gestion** ; qu'elles peuvent, à cette fin, le gérer en **simple régie**, ou encore, s'il s'agit de collectivités territoriales, dans le cadre d'une **régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre** ; qu'elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si **elles créent à cette fin un organisme** dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire […] »

Gestion directe par une (autre) personne publique non juridiquement responsable

2. La gestion par une autre personne, qui n'est pas juridiquement responsable de l'activité d'intérêt général en question.

✓ ***Explication*** **:** cette personne publique s'est vue confier la gestion d'une activité d'intérêt général par la personne publique même qui est juridiquement responsable de l'activité générale dont il s'agit.

*

► Il ne faut pas confondre **lien direct** avec une personne publique et ***gestion en régie***. La première réalité est à la seconde ce que le genre est à l'espèce (1 est plus large que 2 ; 1 englobe 2).

► Il ne faut pas confondre non plus la gestion en régie avec la **régie intéressée** dont il sera question plus loin (Cf. *b – Le lien indirect avec une personne publique*, p. 26).

Dès lors qu'une activité d'intérêt général est gérée par une personne publique, on peut parler de lien direct entre cette activité d'intérêt général et une personne publique.

Mais pour parler, en plus, de gestion en régie, il faut que l'activité d'intérêt général relève de la responsabilité de cette personne publique qui la gère.

Si la personne publique Y s'est vue confier cette activité par une autre personne publique X, on ne peut pas parler de gestion en régie, mais, le plus souvent, de **gestion déléguée** par Y. Et cette gestion déléguée peut prendre l'une des formes décrites dans le ***b*** qui suit.

*

► On présume qu'une activité gérée en régie par une personne publique est une activité de service public. Mais il s'agit d'une présomption simple. Pour être considérée effectivement comme un service public, l'activité doit satisfaire au critère de l'intérêt général analysé ci-dessus (Cf. *1 - Le caractère d'intérêt général de l'activité*, p. 19).

**

b - Le lien indirect avec une personne publique

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. À combien de personnes avons-nous affaire dans l'hypothèse d'un *lien indirect* entre une activité d'intérêt général et une personne publique ?
2. Quelle est la nature juridique de leurs relations ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. À combien de personnes avons-nous affaire dans l'hypothèse d'un lien indirect entre une activité d'intérêt général et une personne publique ?

Dans l'hypothèse d'un ***lien indirect*** entre une activité d'intérêt général et une personne publique, nous avons affaire à ***deux*** personnes :

- d'un côté, la personne publique (appelons-la A) dont relève l'activité d'intérêt général, celle qui en est juridiquement responsable,
- de l'autre, une personne privée (appelons-la B)

2. Quelle est la nature juridique de leurs relations ?

La personne publique (A) ***a confié la gestion*** de l'activité d'intérêt général qui relève d'elle à B. La nature juridique de l'acte par lequel la personne publique (A) a ainsi confié la gestion de l'activité d'intérêt général qui relève d'elle à B détermine la nature juridique des relations entre A et B.

↓ Développement ↓

Lien indirect, habilitation et gestion déléguée : sens de ces mots

► **Dans l'hypothèse du lien indirect, c'est une personne privée qui gère une activité d'intérêt général, mais sous le contrôle d'une personne publique** - cf., par exemple, CE, Sect., 6 avril 2007, *Commune d'Aix-en-Provence*, n° 284736.

➢ La personne privée se voit

- imposer certaines obligations et des mesures permettant de « vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints »[1],
- *éventuellement*, conférer des prérogatives de puissance publique (pour l'essentiel, la possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux).

➢ Dans l'hypothèse du lien indirect, on parle de **gestion déléguée - au sens large de l'expression**. La personne privée est **habilitée** par une personne publique à gérer un service public.

➢ En principe, l'habilitation intervient **a priori**, mais l'idée d'un service public créé spontanément par une personne privée et **reconnu a posteriori** par une personne publique a trouvé

[1] CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541.

une consécration dans l'avis n° 370.169 du Conseil d'État en date du 18 mai 2004 relatif à la Cinémathèque française, association soumise à la loi du 1er juillet 1901 (EDCE 2005, p. 185).

➢ Cette habilitation exprime de la part de la personne publique une **double intention** :

1. L'intention de faire de l'activité en cause une **mission de service public** et

2. L'intention de **confier** cette mission de service public à la personne privée concernée (Voir CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541 : « […] il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission »).

❖ La réalité de cette double intention ne fait pas de doute si la personne publique a conféré à la personne privée des **prérogatives de puissance publique** (pour l'essentiel, la possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux) :

> « [U]ne personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; » - Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541.

❖ En l'absence de l'attribution de prérogatives de puissance publique à la personne privée, le juge déduit la double intention susexposée d'un **faisceau d'indices** :

> « [M]ême en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ; » - Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541.

On aura relevé que dans les deux cas (présence ou absence de prérogatives de puissance publique), la personne publique exerce un **contrôle** sur la personne privée (**habilitation** + **contrôle**). Voir également CE, 8 mars 2012, *Association Nice-volley-ball*, n° 352959.

*

S'agissant de la forme juridique de l'habilitation, plusieurs cas de figure se présentent :

1. La personne privée est une société dont le capital est, au moins, majoritairement public ;

2. La personne privée a reçu d'une personne publique **une autorisation unilatérale**, par un acte réglementaire[1], à l'effet de gérer un service public - **habilitation unilatérale** ;

✓ **Exemple :** les fédérations et les ligues sportives (FFF, FFR, etc.) - CE, Sect., 22 novembre 1974, *Fédération des industries françaises d'articles de sport*, n° 89828 ; CE, 9 juillet 2015, *Football club des Girondins de Bordeaux et autres*, n° 375542. Dans chaque discipline sportive et

[1] C'est ainsi que l'agrément ministériel, prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, qui investit une fédération sportive d'une mission de service public et lui confère qualité pour exercer ces pouvoirs mentionnés audit article, a le caractère d'une décision réglementaire - CE, 20 janvier 1989, *Fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires et Fédération française de judo et jiu-jitsu kendo, disciplines associées*, n° 73962. Solution contraire en l'absence d'une mission de service public : CE, 8 mars 2012 Association Nice-volley-ball, n° 352959.

pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports - Article L131-14 du code du sport.

3. La personne privée a conclu **un contrat** avec une personne publique. Et en vertu de ce contrat, elle gère un service public - **habilitation contractuelle**.

i – La distinction entre les contrats de concession de service public et les marchés de service public

Contrat de délégation de service public et marché de service public

► Les contrats d'habilitation à gérer un service public, qui sont tous des contrats administratifs, relèvent de l'une ou l'autre des **deux** grandes catégories suivantes : **les contrats de concession de service public** et **les marchés de service public** (sachant que les contrats de délégation de service public sont définis comme une sous-catégorie des contrats de concession)**.**

➢ Pour distinguer ces deux catégories de contrats, force est de se fonder sur le code de la commande publique (issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018) qui a rendu quelque peu caduque la jurisprudence établie par la décision CE, 15 avril 1996, *Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc*, n° 168325.

➢ En effet, il résulte du code de la commande publique que la distinction entre les contrats de concession de service public et les marchés de service public repose sur un critère comportant deux aspects complémentaires :

- **le mode de rémunération** du cocontractant, c'est-à-dire de la personne habilitée à gérer le service public (Dans un contrat de concession de service public, la rémunération du cocontractant est liée à l'exploitation du service public ; ce n'est pas le cas dans un marché de service public)
- et **le transfert à cette personne du risque** lié à d'exploitation du service public qui lui a été confié.

➢ Pour savoir si nous avons affaire à un contrat de concession de service public ou à un marché de service public, nous pouvons nous poser

1. soit une **question simple**,
2. soit une **question double**.

Sachant que l'une et l'autre question aboutissent au même résultat, le lecteur de ces lignes est libre de retenir l'une ou l'autre question.

1. Voici la question simple qu'il nous faut poser pour savoir si nous sommes en présence d'un contrat de concession ou d'un marché de service public :

> La personne publique a-t-elle transféré à son cocontractant le **risque** lié à l'exploitation du service public, en contrepartie soit du **droit d'exploiter le service public**, soit de ce droit assorti d'un prix ?

Si oui, nous avons affaire à un contrat de concession de service public.

Sinon, il s'agit d'un marché de service public (Voir schéma, page 35).

2. Et **voici la question double** que nous devons poser pour savoir si nous avons affaire à un contrat de concession de service public ou à un marché de service public :

- La **rémunération** du cocontractant de la personne publique qui confie la gestion du service public est-elle liée à l'exploitation du service public ?

- La personne publique a-t-elle transféré à son cocontractant le **risque** lié à d'exploitation du service dont elle lui a confié la gestion ?

En cas de réponses positives à cette question double (à ces deux questions), nous avons affaire à un contrat de concession de service public.

Sinon, il s'agit d'un marché de service public (Voir schéma, page 35).

*

► **L'enjeu de la distinction** entre les contrats de concession de service public et les marchés de service public réside dans **les règles applicables à la conclusion de ces contrats**, sachant qu'en principe la juridiction administrative est compétente dans tous les cas puisqu'il s'agit, toujours en principe, de contrats administratifs.

➢ La conclusion des contrats de concession de service public est régie par des dispositions spécifiques du code de la commande publique (Partie III de la partie législative du code et partie III de la partie réglementaire du même code).

➢ La passation des marchés de services est soumise à d'autres aux dispositions spécifiques du code de la commande publique (Partie II de la partie législative du code et partie II de la partie réglementaire du même code). Voir schéma, page 35.

*

ii – Définition des contrats de concession de service public et des contrats de délégation de service public

Question préliminaire : Quand faut-il employer l'expression « contrat de concession » ou l'expression « contrat de délégation de service public » (DSP) ?

Réponse : On emploie l'expression **« contrat de délégation de service public »** lorsque la personne publique qui confie contractuellement la gestion du service public **est une collectivité territoriale**[1] (c'est-à-dire, essentiellement, une commune, un département ou une région).

On utilise l'expression **« concession de service public »** lorsque la personne publique qui confie contractuellement la gestion du service public **n'est pas une collectivité territoriale**. Il peut s'agir de l'État, d'une université, d'un hôpital public, donc de toute personne publique autre qu'une collectivité territoriale.

➲ À suivre, les **définitions** du contrat de concession de service public et du contrat de délégation de service public sur une seule page, afin que le lecteur puisse les comparer plus facilement

*

[1] Plus précisément, une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales (Article L.1121-3 du code de la commande publique et article L.1411-1 du code général des collectivités publiques).

❖ La définition du contrat de concession de service public

Le contrat de concession de service public est une sous-catégorie des contrats de concession, lesquels peuvent porter sur des travaux ou des services – voir schéma page 34.

En voici la **définition**, telle que l'impose l'entrée en vigueur, le 1er avril 2019, du code de la commande publique :

✓ Constitue un **contrat de concession de service public** tout contrat par lequel une personne (en principe publique et dénommée « autorité concédante ») confie la gestion d'un service public à une personne privée ou publique (dénommée « concessionnaire »), tout en lui transférant le risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service, soit de ce droit assorti d'un prix – *Code de la commande publique, article L.1121-1*.

► Le droit, reconnu au concessionnaire, d'exploiter le service public se traduit principalement par le droit de prélever sur les usagers de ce service public une rémunération appelée « redevance ».

► Le transfert de risque signifie cumulativement

- que la rémunération du concessionnaire est liée, en tout ou partie, aux résultats de l'exploitation qu'il fera du service public,
- que le concessionnaire est exposé aux aléas du marché,
- que le concessionnaire pourrait donc subir une perte qui n'est pas purement nominale ou négligeable.

*

❖ La définition du contrat de délégation de service public

L'expression « délégation de service public » désigne les contrats de concession conclus par une **collectivité territoriale** (Commune, département, région…).

La **définition du contrat de délégation de service public** est la même que celle du contrat de concession de service public, à un détail près : la personne publique qui confie la gestion du service public est une collectivité territoriale.

✓ Constitue un **contrat de délégation de service public** tout contrat par lequel **une collectivité territoriale** (dénommée « autorité délégante ») confie la gestion d'un service public à une personne privée ou publique (dénommée « délégataire »), tout en lui transférant le risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service, soit de ce droit assorti d'un prix – *Code de la commande publique, article L.1121-3*.

Le commentaire est identique à celui qui concerne le contrat de concession de service public.

► Le droit, reconnu au délégataire, d'exploiter le service public se traduit principalement par le droit de prélever sur les usagers de ce service public une rémunération appelée « redevance ».

► Le transfert de risque signifie cumulativement

- que la rémunération du délégataire est liée, en tout ou partie, aux résultats de l'exploitation qu'il fera du service public,
- que le délégataire est exposé aux aléas du marché,
- que le délégataire pourrait donc subir une perte qui n'est pas purement nominale ou négligeable - *Code de la commande publique, article L.1121-1*.

On considère que le concessionnaire ou le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service.

*****Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions*****
[DÉBUT]

Formes particulières de concession ou de délégation de service public

➢ **L'affermage**[1]. C'est un contrat par lequel une personne publique confie à une personne privée ou publique (dénommée le *fermier*) le soin de gérer un service public à ses frais et risques, moyennant d'une part la perception de *redevances* sur les usagers de ce service, et d'autre part, le versement d'un loyer à la personne publique délégante - CE, 29 avril 1987, *Commune d'Élancourt*, n° 51022.

Le loyer est la contrepartie de l'usage des biens (ouvrages, etc.) que le délégant a mis à la disposition du délégataire. La rémunération du fermier résulte de la différence - supposée positive - entre les redevances et le loyer.

▪ **Différence entre l'affermage et la concession** : le fermier ne conserve pas l'intégralité des redevances reçues des usagers, puisqu'il doit en reverser une partie au délégant.

➢ **La régie intéressée.** C'est un contrat par lequel une personne publique confie à une personne (en principe, une entreprise privée) le soin de gérer un service public, moyennant d'une part des redevances perçues sur les usagers de ce service et reversées intégralement à la personne publique, et d'autre part une rémunération versée par la personne publique et indexée à sur les résultats de l'exploitation du service public.

On l'aura deviné, la rémunération de ce type de contrat comporte, en principe, **deux** parties : une partie fixe forfaitaire et une partie variable (intéressement aux résultats de l'exploitation du service public) destinée à inciter le régisseur à une meilleure gestion et à rendre le service public plus attractif.

▪ **Différences entre la régie intéressée et l'affermage :** le régisseur reverse l'intégralité des redevances à la personne publique, et il est rémunéré par cette dernière.

▪ **Il ne faut pas confondre la régie intéressée avec la gestion en régie.** Lorsque la personne publique qui a la responsabilité d'un service public gère elle-même, directement, ce service public, on parle de gestion en régie, tandis que la régie intéressée implique que cette personne publique confie à une autre personne (publique ou privée) le soin de gérer le service public (voir supra 2 – a Le lien direct avec une personne publique.)

[/FIN]

***

[1] CE, 9 avril 1999, *COMMUNE DE BANDOL*, n° 170999 : « Considérant que la commune de Bandol a confié, par un contrat d'affermage en date du 12 décembre 1973, la gestion de son service des eaux à la Société des Eaux de Marseille; qu'aux termes de ce contrat, les dépenses d'investissement liées à l'entretien du réseau de distribution d'eau et au raccordement des nouveaux usagers demeurent à la charge de la commune ainsi que les dépenses d'achat d'eau auprès des différents fournisseurs ; que le fermier reverse en contrepartie à la commune une fraction des redevances perçues sur les usagers;[…] »

iii – Définition des marchés de service public

► Rappelons que, dans un marché de service public comme dans un contrat de concession ou de délégation de service public, le cocontractant se voit confier la gestion d'un service public.

► Souvenons-nous aussi que, pour savoir si nous avons affaire à un contrat de concession de service public ou à un marché de service public, nous devons poser la question suivante :

> La personne publique a-t-elle transféré à son cocontractant le **risque** lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du **droit d'exploiter le service** qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ?

Si oui, nous avons affaire à un contrat de concession de service public.

Sinon, il s'agit d'un marché de service public.

► Ainsi donc, dans un marché de service public, contrairement à ce qu'il en est dans un contrat de concession ou de délégation de service public,

1. la **rémunération** du cocontractant n'est pas liée aux résultats de l'exploitation **du service public**. Elle réside soit dans le versement d'une somme d'argent par la personne publique qui confie la gestion du service public, soit dans la rétribution par d'autres formes de contreparties (contreparties en nature, exonération de charges, autorisations de percevoir des recettes auprès de tiers, etc.) ;

2. il n'y a pas de **transfert** au cocontractant du **risque** lié à l'exploitation du service public. Le cocontractant ne prend ni n'assume aucun risque.

Voici la **définition** qu'imposent toutes ces précisions :

✓ Constitue **un marché de service public** tout contrat par lequel une personne (en principe publique) confie la gestion d'un service public à une personne privée ou publique, sans transfert de risque, en contrepartie d'une rémunération qui n'est pas liée aux résultats de l'exploitation du service.

Exemple de marché de service public

➢ **Le contrat de gérance** ou **gérance salariée**[1] **:** C'est un contrat par lequel une personne publique confie à une personne (en principe privée) le soin de gérer un service public, moyennant d'une part des redevances perçues sur les usagers de ce service et reversées intégralement à la personne publique, et d'autre part une rémunération forfaitaire versée par la personne publique.

Dans le cadre d'un contrat de gérance, le cocontractant (un simple *gérant*) ne supporte aucun aléa ou quasiment. La personne publique conserve des pouvoirs importants en matière d'organisation du service. Elle fixe les tarifs et supporte le risque sur les coûts (risque industriel) et le risque sur les recettes (risque commercial).

*

[1] Cf. CAA de Nancy, 17 mai 2001, *FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE DES VOSGES*, n° 96NC03097 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de La Bresse a lancé en décembre 1993 un appel de candidatures pour la gestion d'une cafétéria, comprise dans un centre de loisirs alors en cours d'achèvement, sous forme soit de concession, soit de **gérance salariée**, soit de régie intéressée […] »

Les contrats d'habilitation à gérer un service public

(Code de la commande publique – entré en vigueur le 1er avril 2019)

Les contrats présentant les deux caractéristiques suivantes :
1. La **rémunération** du cocontractant **est** liée aux résultats de l'exploitation du service **et**
2. Il y a transfert au cocontractant du **risque** lié à l'exploitation du service.

Les contrats présentant *une* des (ou les *deux*) caractéristiques suivantes :
1. La **rémunération** du cocontractant **n'est pas** liée aux résultats de l'exploitation du service **ou**
2. Il n'y a pas transfert au cocontractant du **risque** lié à l'exploitation du service.

Les contrats de **concession**

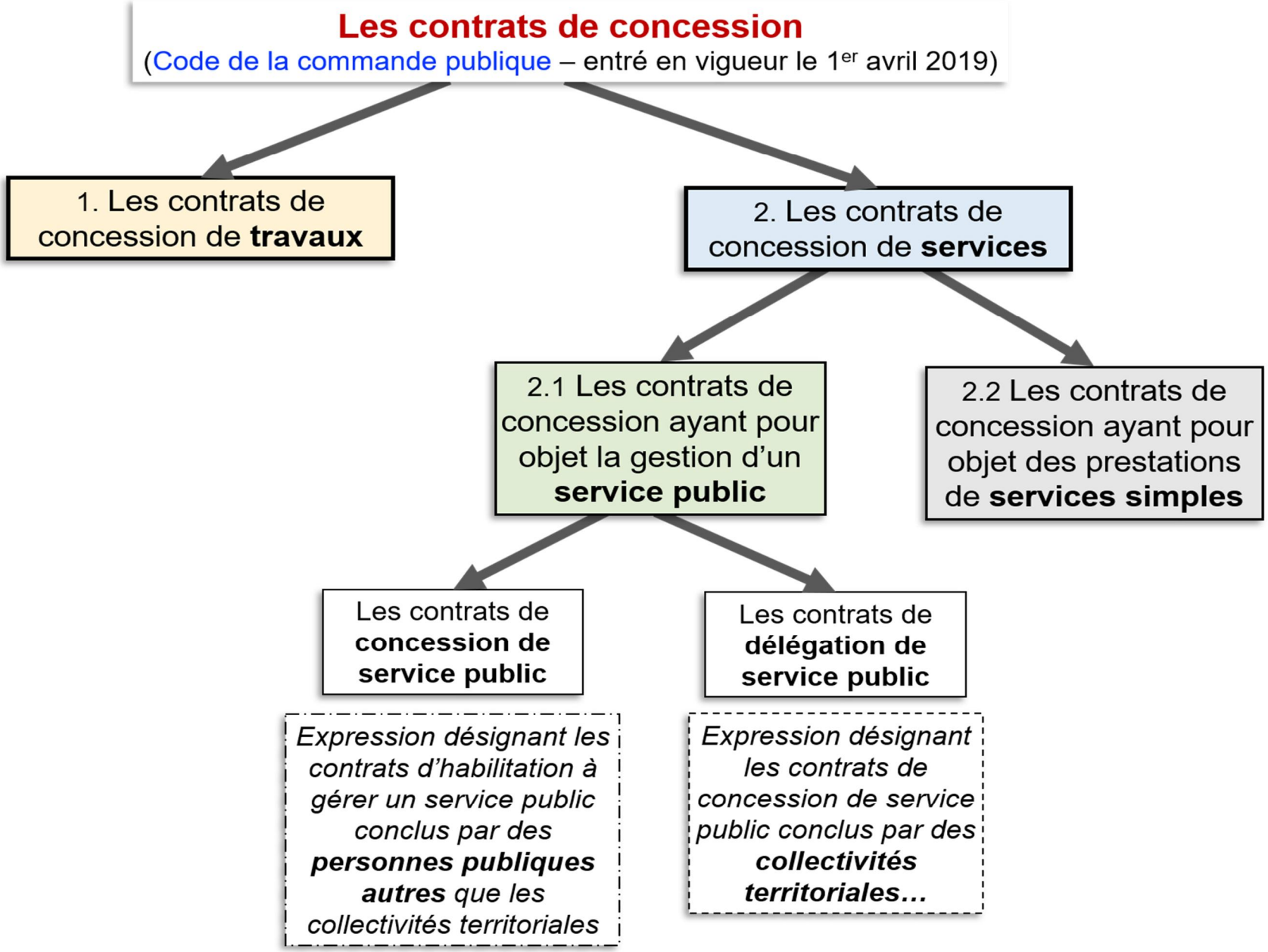
Les contrats de **concession** de service public

Expression désignant les contrats d'habilitation à gérer un service public conclus par des **personnes publiques autres** que les collectivités territoriales

Les contrats de **délégation** de service public

Expression désignant les contrats de **concession** de service public conclus par des **collectivités territoriales…**

Les **marchés** de service public


Les contrats de concession
(Code de la commande publique – entré en vigueur le 1er avril 2019)
1. Les contrats de concession de travaux
2. Les contrats de concession de services
2.1 Les contrats de concession ayant pour objet la gestion d'un service public
2.2 Les contrats de concession ayant pour objet des prestations de services simples
Les contrats de concession de service public
Les contrats de délégation de service public
Expression désignant les contrats d'habilitation à gérer un service public conclus par des personnes publiques autres que les collectivités territoriales
Expression désignant les contrats de concession de service public conclus par des collectivités territoriales…

Contrat de concession de service public ou marché de service public ?

Contrats à qualifier	Situation financière du cocontractant de l'administration		Nature du contrat		Droit applicable et juge compétent	
	Rémunération liée à l'exploitation du service public ?	Transfert du risque lié à l'exploitation du service public ?	Contrat de concession de service public ?	Marché de service public ?	CCP (L.III, R.III) et juge administratif ?	CCP (L.II, R.II) et juge administratif ?
Contrat A	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	NON
Contrat B	OUI	NON	NON	OUI	NON	OUI
Contrat C	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
Contrat D	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI

iv – La problématique des redevances

► Le Conseil d'État **définit les redevances** de la manière suivante :

> Constituent des **redevances** les sommes « demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouvent leur contrepartie directe dans des prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage » - CE, Ass., 21 novembre 1958, *Syndicat national des transporteurs aériens*, n° 30693-33969.

► **La légalité de l'établissement d'une redevance est subordonnée à trois conditions :**

1. La redevance doit porter sur un service qui par nature peut donner lieu à la perception d'une redevance. En effet, certains services publics ne peuvent être financés que par l'impôt ; c'est, en principe, le cas de la police ;

2. La redevance doit correspondre à un service rendu à l'usager. Ce n'est donc ni un impôt ni une taxe. En l'absence de service directement rendu à l'usager qui l'acquitte, la redevance est illégale[1]. De même, une redevance ne peut pas, en principe, servir à financer un autre service ou ouvrage que celui utilisé par les usagers auxquels elle est demandée ;

3. Enfin, le montant de la redevance doit correspondre au coût réel du service rendu. Il doit donc y avoir une certaine équivalence entre la redevance et le coût réel du service. Toutefois, par pragmatisme, le juge se contente d'exercer un contrôle restreint sur le respect de cette condition légale. L'administration bénéficie ainsi d'une certaine latitude. Le juge ne censure que les disproportions manifestes entre le montant de la redevance et le coût réel du service rendu[2].

*****Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions*****
[DÉBUT]

✓ **<u>Précisions</u>** apportées par la décision CE, Ass., 16 juillet 2007, *Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et autre*, n° 293229 et 293254 :

« Considérant que, pour être légalement établie -et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles- une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, **si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie** ; qu'il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le **prix de revient** de ce dernier, mais aussi, en fonction des **caractéristiques du service**, en tenant compte de la **valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire** ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères **objectifs et rationnels**, dans le respect du **principe d'égalité** entre les usagers du service public et des règles de la concurrence ; »

✓ **Précision** apportée par la décision CE, 11 juillet 2019, *EARL Plaine de Vaucouleurs*, n° 422577 :

Si une délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale modifie les tarifs d'une **redevance pour service rendu** en prévoyant **une date d'entrée en vigueur rétroactive**, cette délibération est

---

[1] CE, 18 janvier 1985, *D'Antin de Vaillac et autres*, n° 25161 28076 ; CE, 13 novembre 1987, *Syndicat national des transports aériens*, n° 57652 57653.

[2] CE, 17 novembre. 1978, *Société Établissements Geismann frères*, n° 00262 ; CE, 24 janvier, 1986, *Ministre de l'Urbanisme*, n° 60777 61305 ; CE, 2 novembre 1987, *Mansier*, n° 57051; CE, 3 juillet. 1991, *Syndicat des psychiatres des hôpitaux*, n° 49253 49264 50211 50217 50355 50608 56084 84859.

entachée d'illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d'augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

[/FIN]

***

Définition du service public : rappel

► *C'est une activité assurée par une personne publique ou par une personne privée (avec l'habilitation et sous le contrôle d'une personne publique) en vue, principalement, de répondre à un besoin d'intérêt général*[1].

➢ **Cette définition**, dont chacun des mots compte, **résulte d'une évolution jurisprudentielle nuancée que vous n'êtes évidemment pas tenu (e) de retenir dans son intégralité :**

✓ **Une personne privée peut gérer un service public :** CE, Ass., 20 décembre 1935, *Société anonyme des Établissements Vezia*, n° 39234 ; CE, Ass., 13 mai 1938, *Caisse primaire Aide et Protection*, n° 57302 ; CE, Sect., 13 janvier 1961, *Magnier*, Rec., p. 33 ; CE, Sect., 22 novembre 1974, *Fédération des industries françaises de sport*, n° 89828 : les fédérations sportives gèrent un service public à caractère administratif ; CE, Sect. int. Avis, 7 octobre 1986, Champ d'application et financement de la gestion déléguée, n° 340609 ;

✓ **Une personne privée n'est réputée gérer un service public que si trois conditions sont réunies** - CE, Sect., 28 juin 1963, *Sieur Narcy*, Rec., p. 401 ; TC, 5 juillet 1982, *Mlle Nicolet*, n° 02235 ; CE, 16 novembre 1988, *Mlle Denjean*, n° 70099 et 70269 ; CE, 22 mars 2000, *Lasaulce*, n° 207804 :

1. Caractère d'intérêt général de l'activité,

2. Contrôle exercé par une personne publique et

3. Détention par la personne privée de prérogatives de puissance publique (c'est-à-dire, essentiellement, la possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux).

✓ Assouplissement de la jurisprudence *Narcy* précitée. **Même si elle ne détient pas de prérogatives de puissance publique, une personne privée est réputée gérer un service public si deux conditions sont réunies :**

1. Caractère d'intérêt général de l'activité et

2. Contrôle exercé par une personne publique.

Ce dernier assouplissement est dû essentiellement aux décisions suivantes : CE, 20 juillet 1990, *Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs*, n°s 69867 et 72160 ; TC, 25 mars 1996, *Préfet de la Gironde*, n° 02991 ; CE, Sect., 22 février 2007, *Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés* (A.P.R.E.I.), n° 264541 et CE, 5 octobre 2007, *Société UGC-Ciné-Cité*, n° 298773.

Cf. également divers schémas à la fin de ce document.

[1] Une activité peut remplir tous ces critères et n'être pas considérée comme un service public. Par exemple, pour le juge administratif, la gestion du domaine privé d'une personne publique ne constitue pas un service public.

II - Le régime du service public

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Que faut-il entendre par *régime du service public* ?
2. Quelles règles faut-il garder à l'esprit une fois que l'on a appris à définir le service public ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Que faut-il entendre par "régime du service public" ?

Par ***régime du service public***, il faut entendre les règles applicables aux services publics et qu'il faut garder à l'esprit.

2. Quelles règles faut-il garder à l'esprit une fois que l'on a appris à définir le service public ?

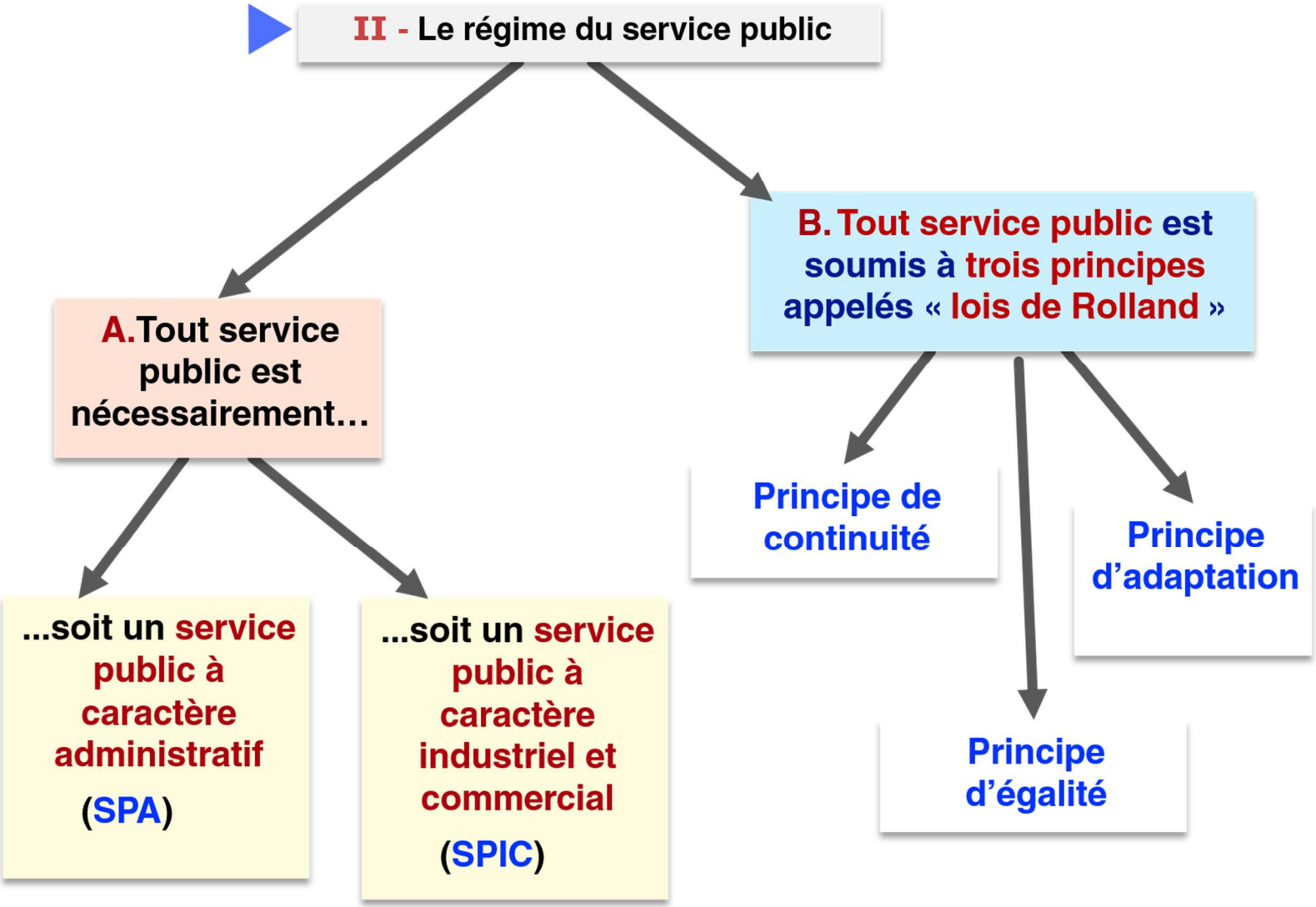
Pour l'essentiel, ces règles sont au nombre de deux :

a. Tout service public est *nécessairement*

- soit un ***service public à caractère administratif***,
- soit un ***service public à caractère industriel et commercial***

b. Tout service public est *nécessairement* soumis aux ***trois lois du service public*** : principe de continuité, principe d'adaptation et principe d'égalité.

↓ Développement ↓


II - Le régime du service public
A. Tout service public est nécessairement…
B. Tout service public est soumis à trois principes appelés « lois de Rolland »
…soit un service public à caractère administratif (SPA)
…soit un service public à caractère industriel et commercial (SPIC)
Principe de continuité
Principe d'égalité
Principe d'adaptation

A - La *summa divisio* : S.P.A. ou S.P.I.C.

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Pourquoi qualifie-t-on de *summa divisio* la distinction "service public à caractère administratif (SPA) – service public à caractère industriel et commercial (SPIC)" ?
2. Qui peut gérer un service public à caractère administratif et qui peut gérer un service public à caractère industriel et commercial ?
3. Quel rapport y a-t-il entre *établissement public* et *service public* ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Pourquoi qualifie-t-on de *summa divisio* la distinction "service public à caractère administratif (SPA) – service public à caractère industriel et commercial (SPIC)" ?

On peut classer les services publics en se fondant sur les critères les plus divers, mais la distinction ***SPA-SPIC*** emporte les conséquences juridiques les plus importantes : soumission globale, mais pas exclusive, du SPA au droit administratif et du SPIC au droit privé.

2. Qui peut gérer un service public à caractère administratif et qui peut gérer un service public à caractère industriel et commercial ?

Un service public à caractère administratif **peut** être géré par une personne publique ou par une personne privée. De même, la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial **peut** être le fait d'une personne publique ou d'une personne privée.

3. Quel rapport y a-t-il entre "établissement public" et "service public" ?

Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de dire qu'un établissement public est un service public. Ce serait comme si vous disiez qu'une commune est un service public. Nous avons déjà parlé de l'établissement public dans l'analyse du lien avec une personne publique.

► ***Définition*** : L'établissement public est une personne morale de droit public chargée principalement (spécialement) de gérer un service public.

Exemples : Météo France, les universités…

Si le service public géré par l'établissement public est un service public à caractère administratif, l'établissement public est qualifié d'***établissement public à caractère administratif***. Exemples : les universités, Pôle emploi[1], le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou.

Si l'établissement public gère un service public à caractère industriel et commercial, on le qualifie d'***établissement public à caractère industriel et commercial***. Exemples : la Cité des Sciences et de l'Industrie, le Théâtre National de l'Opéra de Paris, la RATP.

Certains établissements publics gèrent à la fois un service public à caractère administratif et un service public à caractère industriel et commercial. On les qualifie d'***établissements publics à double visage*** (C'est le cas de l'Office national des forêts - ONF).

↓ Développement ↓

[1] CE, 23 juillet 2014, *SUD travail-affaires sociales*, n° 363522.

1 – Le caractère exhaustif de la distinction

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Question initiale :

► En quoi la distinction SPA-SPIC est-elle exhaustive ?

Réponse soutenue et développée dans ce cours :

➢ La distinction SPA-SPIC est exhaustive pour la raison suivante : ***aucun service public n'y échappe***.

↓ Développement ↓

Un service public est forcément soit un SPA, soit un SPIC

► Un service public a, nécessairement, soit un caractère administratif (**SPA**), soit un caractère industriel et commercial (**SPIC**).

Cependant, on a soutenu naguère que, confronté au cas des colonies de vacances, le Tribunal des conflits avait consacré une troisième catégorie de services publics : celle des services publics visant un « but d'intérêt social » et soumis à un régime de droit privé – TC, 22 janvier 1955, *Naliato c/ État*, n° 1511. Mais cette interprétation peu réaliste a été abandonnée : TC, 4 juillet 1983, *Gambini c/ Ville de Puteaux*, n° 02306.

➢ Certains établissements publics assurent plusieurs activités de service public dont les unes ont un caractère administratif, et les autres un caractère industriel et commercial. On les qualifie d'**établissements publics mixtes** ou **à double visage. *Exemples* :** Office national des forêts[1] ; chambres de commerce et d'industrie[2] ; ports[3]…

▪ **Il est des qualifications qui ne doivent pas donner le change.**

Par exemple, le code de l'Éducation qualifie les universités d'*établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel*. En fait, elles gèrent un service public à caractère administratif, celui de l'enseignement et de la recherche. Il s'agit donc d'**établissements publics à caractère administratif**.

▪ On peut donc estimer que la distinction *service public à caractère administratif - service public à caractère industriel et commercial* constitue le plan de clivage des activités de service public. Cette distinction a été affirmée, pour la première fois avec éclat, dans l'arrêt TC, 22 janvier 1921,

[1] TC, 9 juin 1986, *Commune de Kintzheim c/ ONF*, n° 02428.
[2] TC, 23 février 1981, *Crouzel et chambre de commerce et d'industrie de Périgueux c/ Consorts Boisseau*, n° 02178.
[3] CE, 17 avril 1959, *Sieur Abadie*, Rec. p. 239.

Colonie de la Côte d'Ivoire c. Société commerciale de l'Ouest africain, n° 00706 – arrêt dit du *Bac d'Eloka*[1].

**

2 – L'intérêt de la distinction

Droit applicable et juge compétent

► **La distinction présente surtout un intérêt contentieux.**

▪ L'activité du service public à caractère administratif relève *globalement* du droit administratif, celle du service public à caractère industriel et commercial du droit privé.

▪ Les rapports du service public à caractère administratif avec son personnel[2], ses usagers et les tiers sont *globalement* soumis au droit administratif. Ceux du service public à caractère industriel et commercial avec ses usagers ou avec les tiers[3] au droit privé.

▪ Le contentieux des services publics à caractère administratif ressortit *globalement* à la compétence des juridictions administratives, celui des services publics à caractère industriel et commercial relève de la compétence des juridictions judiciaires.

➢ En résumé, il existe

▪ s'agissant des services publics à caractère administratif, un bloc de compétence en faveur du juge administratif ;

▪ et, en ce qui concerne les services publics à caractère industriel et commercial, un bloc de compétence en faveur du juge judiciaire.

➢ Toutefois, ces deux blocs de compétence souffrent quelques exceptions présentées ci-après et exclues des révisions : **nuances contentieuses**.

******Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions***** [DÉBUT]

► **Nuances contentieuses.** Bien qu'exclues des révisions, elles méritent d'être signalées :

➢ **Exceptions au régime contentieux des services publics à caractère administratif.** Par dérogation au principe de la compétence du juge administratif, **le juge judiciaire a compétence pour statuer sur** :

- un litige *contractuel* opposant l'agent d'un service public à caractère administratif à la personne *privée* qui gère ce service public – CE, 4 avril 1962, *Chevassier* ;
- un litige (*non contractuel*) opposant l'agent d'un service public à caractère administratif à la personne *privée* qui gère ce service public dans le cas où le litige résulte d'un *acte unilatéral* concernant l'agent – TC, 20 novembre 1961, *Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis* ;

---

[1] Dans cette décision, le Tribunal des conflits estime que « la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport *dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire* ».

[2] Cf. TC, 25 mars 1996, *Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud'hommes de Lyon*. Cet arrêt met fin à une jurisprudence on ne peut plus byzantine. La règle est désormais simple : « [L]es personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. » Bien entendu, les personnels statutaires sont des fonctionnaires et donc, également, des agents publics.

[3] TC, 11 juillet 1933, *Dame Mélinette*, n° 00784.

➢ **Exceptions au régime contentieux des services publics à caractère industriel et commercial.** Par dérogation au principe de la compétence du juge judiciaire, **le juge administratif a compétence pour statuer sur les litiges suivants :**

- un litige consécutif au dommage de travaux publics subi par un tiers (pas un usager !) au service public à caractère industriel et commercial - CE, Sect. 25 avril 1954, *Dame veuve Barbaza et société d'assurances "La mutuelle générale française" n° 8477 et 12435* ; TC, 2 mars 1987, *Compagnie La Lutèce,* n° 02461 ; (Solution inverse pour l'usager : TC, 25 juin 1954, *Galland, Guyomar et Salel* - Primauté de la responsabilité contractuelle sur la responsabilité quasi délictuelle, même s'il s'agit de la responsabilité pour dommages de travaux publics, pourtant attractive.) ;
- les litiges ayant trait aux décisions réglementaires relatives à l'organisation du service public à caractère industriel et commercial - TC, 15 janvier 1968, *Cie Air France c/ Époux Barbier*, n° 01908, Rec., p. 789, concl. Kahn. Précisions apportées par la décision CE, 3 octobre 2003, *M. Peyron*, n° 242967 : « [Considérant] que si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu'elles sont présentées par un usager, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l'organisation d'un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l'usage des installations, il n'en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l'application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles ; » En d'autres termes, relèvent du juge administratif les litiges consécutifs à l'acte par lequel sont fixés les tarifs ,car cet acte est relatif à l'organisation du service ; à l'inverse relèvent du juge judiciaire les litiges concernant l'acte par lequel les tarifs sont appliqués à un usager[1] ;
- les litiges liés à l'exercice de *prérogatives de puissance publique* - CE, Sect., 13 octobre 1978, *Assemblée départementale pour l'aménagement des structures agricoles du Rhône*, n° 03335 ;
- un litige relatif à la *situation contractuelle soit du directeur général, soit du comptable public* du service public à caractère industriel et commercial géré par une personne publique – CE, Sect., 8 mars 1957, *Jalenques de Labeau* ;

[/FIN]

***

Qui peut gérer un SPA **? Qui peut gérer un** SPIC **?**

► **Malgré ces différences de régime**,

- ➢ **un service public à caractère administratif peut être géré par une personne publique ou par une personne privée**.
- ➢ De même, **la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial peut être le fait d'une personne publique ou d'une personne privée**.

**

[1] Cf. aussi CE, 26 juin 1989, *Association Études et consommation CFDT*, n° 91356.

3 – Les critères de la distinction

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. À quoi reconnaît-on un service public à caractère administratif ?
2. À quoi reconnaît-on un service public à caractère industriel et commercial ?
3. Quelle doit être ma démarche lorsque l'on me demande si un service public X est un service public à caractère administratif (SPA) ou un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. À quoi reconnaît-on un service public à caractère administratif ?

Par son objet, l'origine de ses ressources ou les modalités de son fonctionnement, un service public à caractère administratif **se distingue** d'une entreprise privée.

2. À quoi reconnaît-on un service public à caractère industriel et commercial ?

Par son objet, l'origine de ses ressources ou les modalités de son fonctionnement, un service public à caractère industriel et commercial **ressemble** à une entreprise privée.

Relevons avec une relative satisfaction un écho de cette définition dans la jurisprudence de la Cour de cassation : « [P]our être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement » - civ. 1e 11 février 2009, pourvoi n° 07-19326.

3. Quelle doit être ma démarche lorsque l'on me demande si un service public X est un service public à caractère administratif (SPA) ou un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) ?

Si l'on me pose une telle question, ma démarche sera la suivante :

Étape n° 1. Je me demande si la loi a qualifié de SPA ou de SPIC ce service public X. Dans l'affirmative, ma tâche est terminée, je ne passerai pas à l'étape n° 2 : je dirai, comme le ferait le juge, que le service public X en question est, selon la qualification législative découverte, un SPA ou un SPIC. Dans la négative, donc en cas l'absence de qualification législative, je passerai à l'étape n° 2 qui suit.

Étape n° 2. Je me demande si le service public X en cause remplit les critères jurisprudentiels requis pour la qualification de SPA ou de SPIC. Selon que la réponse à cette dernière question sera positive ou négative, je conclurai que j'ai affaire un SPA ou à un SPIC.

↓ Développement ↓

La présomption

❖ **Un service public est présumé administratif**, et cette présomption ne cède que s'il résulte soit d'une disposition législative, soit des critères jurisprudentiels exposés ci-après que ce service public a un caractère industriel et commercial.

La présence d'une qualification législative directe ou indirecte

►La distinction *service public à caractère administratif – service public à caractère industriel et commercial* ne soulève pas de difficulté dans le cas d'une **qualification législative** : le juge prend acte de la volonté parlementaire, applique la loi et retient *ipso facto* la qualification donnée par le législateur – TC, 29 décembre 2004, *Époux Blanckeman c/ Voies navigables de France*, n° C3416.

L'absence de qualification législative directe ou indirecte : le recours à des critères

►**Faute de qualification législative et alors même qu'il serait en présence d'une qualification « administrative » donnée par voie réglementaire** (laquelle ne le lie pas)[1]**, le juge retient trois critères** - CE, Ass., 16 novembre 1956, *Union syndicale des industries aéronautiques* (arrêt dit « USIA »), Rec. p. 434.

▪ C'est l'examen de ces trois critères qui fera apparaître un service comme un service public à caractère administratif ou comme un service public à caractère industriel et commercial. Néanmoins, ces trois critères ne sont pas nécessairement cumulatifs – le juge n'exige pas forcément qu'ils soient tous orientés dans un sens (CE, Avis, 27 octobre 2000, n° 222672 ; TC, 21 mars 2005, *Alberti Scott*, n° C3413). Aucun de ces critères ne peut être considéré a priori comme décisif – le juge apprécie au cas par cas, **sachant qu'un service public est présumé avoir un caractère administratif**.

▪ **1er critère : le critère de l'objet**. Si l'objet du service public l'apparente à une entreprise privée, on est, probablement, en présence d'un service public à caractère industriel et commercial. Ce qui compte, ce sont les caractères de l'activité du service public. Si le service public n'exerce pas une activité qui pourrait être le fait d'une entreprise privée, on a affaire, *peut-être*, à un service public à caractère administratif ;

✓ ***Exemple*** : L'Établissement français du sang gère un service public à caractère administratif. En effet, sa « mission de santé publique se rattache par son **objet** au service public à caractère administratif, alors même qu'une part importante des ressources de l'établissement français du sang est constituée par la cession de produits sanguins labiles et que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de cet établissement, précisé par le décret n° 99-143 du 29 décembre 1999, fait application de règles adaptées à la nature particulière de ses missions et qui peuvent être semblables à celles généralement appliquées aux établissements publics industriels et commerciaux ». - CE, Avis, 27 octobre 2000, n° 222672.

---

[1] En présence d'une qualification donnée par **décret**, le juge recherche si elle est conforme au caractère véritable du service. Ainsi, la qualification d'établissement public industriel et commercial donnée par décret au Fonds de régularisation des marchés agricoles (supprimé depuis 1986), a été contredite par le Tribunal des conflits, qui a estimé qu'il exerçait une action purement administrative : TC, 24 juin 1968, *Société Distilleries bretonnes*, n° 01917. C'est ce que l'on appelle un établissement public à **visage inversé**.
Il en a été de même pour le Centre français du commerce extérieur, qualifié d'établissement public industriel et commercial par **décret** : TC, 26 octobre 1987, *Centre français du commerce extérieur c/ Mme Mourot*.

▪ **2e critère : le critère de l'origine des ressources**. C'est une donnée objective, quantifiable.

Si le service public est financé, ne serait-ce que partiellement (TC, 21 mars 2005, *Alberti Scott*, n° C3413), au moyen de redevances payées par les usagers, il a, *sans doute*, un caractère industriel et commercial. Si ses ressources proviennent exclusivement de subventions publiques ou de recettes fiscales, il s'agit, *vraisemblablement*, d'un service public à caractère administratif.

✓ ***Exemple*** : affaire *Union syndicale* précitée[1].

▪ **3e critère : le critère des modalités de fonctionnement**. Parfois, elles opposent le service public aux entreprises privées. Grande est alors la *probabilité* qu'il s'agisse d'un service public à caractère administratif.

✓ ***Exemple*** : un service public excluant toutes possibilités de bénéfice - il fonctionne à prix coûtant ou gratuitement[2] ; service public exerçant des prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire prenant des actes administratifs unilatéraux - le plus souvent de caractère individuel.

► **Rappelons qu'il faut comprendre ces trois critères** de la manière indiquée par le commissaire du gouvernement Didier Chauvaux dans ses conclusions sur l'avis, précité, rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 2000, n° 222672 :

« **Un service public est présumé présenter un caractère administratif**.

Cette présomption ne cède que si trois conditions se trouvent remplies simultanément.

Pour reprendre les termes utilisés par le président Odent dans son *Cours de contentieux administratif*, il faut que le service public "ne se distingue pas d'une entreprise privée,

- en premier lieu par son objet (c'est-à-dire que les opérations auxquelles il se livre doivent être de la même nature que celles auxquelles une entreprise privée pourrait se livrer),

- en second lieu par ses modes de financement (c'est-à-dire qu'il doit être principalement alimenté par les redevances payées par les usagers en rémunération des services qu'il leur assure et non par des subventions budgétaires),

- en troisième lieu enfin par ses procédés de gestion (c'est-à-dire qu'il doit être géré selon les règles du droit privé)". »

► **La Cour de cassation adhère à cette présomption du caractère administratif des services publics :** « [I]l incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d'un service public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement […] » - Cass. civ., 1e, 31 mars 2010, pourvoi n° 09-12821.

► Si le doute persiste, la détention de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire le droit de prendre des actes administratifs unilatéraux[3] fait présumer le caractère administratif du service public en cause – Il s'agit d'une présomption simple.

► Un service public fonctionnant en situation de monopole n'est pas nécessairement un service public à caractère administratif[4].

---

[1] On s'explique mieux sa générosité.

[2] TC, 24 décembre 1994, *Préfet de Mayotte*, n° 02937.

[3] CE, Sect., 13 octobre 1978, *ADASEA du Rhône*, n° 03335.

[4] TC, 22 février 1960, *Société Pétronaphte*, Rec. 857, AJDA 1960, p. 102.

Définitions du SPA et du SPIC

► **Pour résumer,**

✓ **Définition :** un **service public à caractère administratif** est un service public que son objet, l'origine de ses ressources ou les modalités de son fonctionnement distinguent d'une entreprise privée.

✓ **Définition :** un **service public à caractère industriel et commercial** est un service public que son objet, l'origine de ses ressources ou les modalités de son fonctionnement apparentent à une entreprise privée.

*

Exemples de SPA et de SPIC

Exemples de qualification

► Rappelons qu'en fait de qualification **le caractère administratif d'un service public est présumé**.

Didier Chauvaux, dans ses conclusions sur l'avis n° 222672, précité, rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 2000, le souligne :

« Un service public est présumé présenter un caractère administratif.

Cette présomption ne cède que si trois conditions se trouvent remplies simultanément. »

La Cour de cassation adhère à cette présomption du caractère administratif des services publics :

« [I]l incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d'un service public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement […] » - Cass. civ., 1e, 31 mars 2010, pourvoi n° 09-12821.

► **Ont donc été reconnus comme ayant un caractère industriel et commercial :**

▪ en raison de son seul objet, le service public de la distribution de l'eau - TC, 21 mars 2005, *Mme Alberti-Scott*, n° C3413[1] ;

▪ l'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune - CE, 19 février 2009, *Beaufils*, n° 293020 ;

[1] « Considérant que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ; qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu'en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager ; » - TC, 21 mars 2005, *Mme Alberti-Scott*, n° C3413.

▪ le service d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'une commune décide de le financer par une redevance pour service rendu, dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères - CE, Sect., Avis, 10 avril 1992, *SARL Hofmiller*, n° 132539.

► **En revanche, ont été jugés avoir un caractère administratif**

▪ **le service public autoroutier -** TC, 20 novembre 2006, *Société EGTL c/ Escota*, n° C3569

« Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; »

▪ **les piscines municipales** - TC, 9 janvier 2017, Société Centre Léman c/ communauté d'agglomération d'Annemasse - Les Voirons, n °4074 :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre aquatique Château bleu, qui comprend notamment une piscine olympique et un espace « bien-être » doté d'une salle de « cardio-fitness », d'un sauna, d'un hammam et d'un bain à remous, propose des activités d'« aqua-gym » et d'« aqua-bike » ; que ce centre est exploité directement par la communauté d'agglomération d'Annemasse - Les Voirons, qui en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ; que les produits et charges d'exploitation sont portés au budget de la communauté d'agglomération ; qu'eu égard à son organisation et à ses conditions de fonctionnement, le centre ne saurait être regardé comme un service public industriel et commercial ; qu'il présente par suite, pour l'ensemble de ses activités, un caractère administratif ; »

S'agissant des piscines municipales, voir aussi : CE, Sect., 14 juin 1963, *Époux Hébert*, Rec. p 364 (espèce relative à la noyade d'un adolescent de 14 ans) ; CE, 9 juillet 1975, *Ville de Cognac*, Rec. p 413 ; CE, 12 janvier 1977, *Commune de Saint-Pierre-de-Trivisy*, n° 94884.

*

➢ **Le doyen Maurice Hauriou** protestait déjà contre la prolifération des services publics à caractère industriel et commercial : « L'État n'est pas une association pour travailler ensemble à la production des richesses, il est seulement pour les hommes une certaine manière d'être ensemble, de vivre ensemble, ce qui est essentiellement le fait politique. Si l'État entreprend de satisfaire des intérêts d'ordre économique, si des entreprises agricoles et industrielles deviennent des membres de l'État, **nous disons que c'est grave, parce qu'on nous change notre État**. » - Note sous TC, 9 décembre 1899, *Association syndicale du Canal de Gignac*, n° 00515.

SPA ou SPIC ?

Services public à qualifier	Le service public à qualifier ressemble-t-il à une entreprise privée...			Nature de ce service public :		Droit applicable et juge compétent (globalement)	
	...par son objet ?	...par l'origine de ses ressour-ces ?	...par les modalités de son fonction-nement ?	SPA ?	SPIC ?	Droit admini-stratif et juge admini-stratif ?	Droit privé et juge judiciaire ?
Service public A	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	NON	OUI
Service public B	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	NON
Service public C	OUI	NON	NON	Peut-être	Peut-être	Peut-être	Peut-être
Service public D	NON	OUI	OUI	Peut-être	Peut-être	Peut-être	Peut-être
Service public n...				Peut-être	Peut-être	Peut-être	Peut-être

B - Les lois du service public

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. Que faut-il entendre par *lois du service public* ?
2. Quelles sont ces lois ?
3. Qu'est-ce qui justifie l'existence de ces lois ?
4. Ces lois ont-elles une valeur absolue ? Autrement dit, sont-elles appliquées sans nuances ni dérogations ?
5. Quel rapport y a-t-il entre ces lois et le *principe de la légalité* ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. Que faut-il entendre par "lois du service public" ?

Par ***lois du service public***, il faut entendre non pas des lois votées par le Parlement, mais des ***principes*** applicables à tous les services publics. Cela dit, il existe des lois votées par le Parlement et qui s'appliquent aux services publics.

2. Quelles sont ces lois ?

Ces lois sont au nombre de ***trois*** : le principe de continuité, le principe d'adaptation ou de mutabilité et le principe d'égalité.

La gratuité n'est pas un principe général : CE, Ass., 10 juillet 1996 *Société Direct Mail Promotion et autres*, n° 168702 168734 169631 169951.

3. Qu'est-ce qui justifie l'existence de ces lois ?

L'existence de ces lois est justifiée par les exigences de ***l'intérêt général***. N'oublions pas que l'intérêt général est l'un des deux éléments de la définition du service public.

4. Ces lois ont-elles une valeur absolue ? Autrement dit, sont-elles appliquées sans nuances ni dérogations ?

Chacune de ces lois admet quelques dérogations dictées par l'intérêt général.

5. Quel rapport y a-t-il entre ces lois et le ***principe de la légalité*** ?

Ces lois font partie des exigences du **principe de la légalité**.

↓ Développement ↓

Origine de l'expression « lois de Rolland »

► **Louis Rolland** observe : « En France, tous les services publics sont soumis à un minimum de règles générales de conduite, de "lois" auxquelles échappent les entreprises privées. C'est de cette façon qu'apparaît un minimum, pour les services publics, de régime spécial. Ces règles de conduite, ces lois applicables toujours et nécessairement au service public sont peu nombreuses, il y en a trois : la loi de continuité, la loi de changement et la loi d'égalité. [1] »

➢ La postérité doctrinale a baptisé ces règles « **lois de Rolland** ». Ces « lois » - qui ne sont pas des lois au sens parlementaire du mot, mais des principes - font partie des exigences du principe de la légalité.

1 - Le principe de continuité

Raison d'être et définition du principe de continuité

► Le service public a été créé ou reconnu comme tel pour faire face, non à un caprice, mais à un besoin d'intérêt général. Par définition, ce besoin est continu. En conséquence, le service public *doit fonctionner sans solution de continuité, sans interruptions intempestives.*

> ✓ **Définition :** le **principe de continuité du service public**, c'est le principe (ou la règle) selon lequel le fonctionnement du service public doit être assuré de manière régulière ou constante.

▪ Toutefois, *fonctionner continuellement n'est pas fonctionner continûment*. Le principe de continuité s'accommode des interruptions fondées sur les textes, l'intérêt général ou la nature des choses.

► Pour le Conseil constitutionnel, la continuité du service public constitue un **principe de valeur constitutionnelle** : Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, *Droit de grève à la télévision et à la radio*.

► Selon le Conseil d'État, il s'agit d'un « **principe fondamental** »[2] : CE, 13 juin 1980, *Madame Bonjean*, n° 17995. Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, ce principe n'empêche pas l'administration de mettre fin à un service public lorsqu'elle l'estime nécessaire – CE, 18 mars 1977, *Chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle*, n° 97939 97940 97941.

Conséquences découlant du principe de continuité

► Le principe de continuité emporte certaines **conséquences** :

1. Conséquences sur la gestion des services publics. Par exemple, le concessionnaire d'un service public doit assurer, de manière régulière, le service public qui lui a été délégué. Il n'est libéré de cette obligation que par la force majeure ou le comportement de l'administration rendant impossible l'exécution du service[3]. Hors ces cas, interrompre le service public est une faute pouvant entraîner la *déchéance* (l'éviction) du concessionnaire ;

---

[1] *Cours de droit administratif*, 1943 - 1944.

[2] Entendre par là « principe général du droit ». Quatre ans plus tôt, le Conseil d'État parlait simplement de « principe de continuité du service public » – CE, Sect., 30 mars 1979, *Secrétaire d'État aux universités*, n° 09369.

[3] CE, 3 mars 2017, *Commune de Clichy-sous-Bois*, n° 398901 : Dans le cadre d'une concession, les principes de continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public ne s'imposent au concessionnaire que dans les limites de l'objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations.

2. Conséquences sur l'exécution des contrats d'habilitation à gérer un service public.

Parfois, l'administration doit venir en aide à son cocontractant lorsque ce dernier ne parvient pas à assumer financièrement l'exécution du service public qui lui a été confié – Ce principe vaut d'ailleurs pour tous les contrats administratifs – Cf. Contrats. En cas d'urgence ou d'impuissance de l'administration, le juge peut ordonner, éventuellement sous menace de sanctions pécuniaires, audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public[1] ;

3. Conséquences sur le droit de grève.

✓ ***Définition*** : la **grève**[2] est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications d'ordre professionnel.

➢ Naguère, le principe de continuité faisait obstacle d'une manière générale et absolue à la grève dans les services publics - CE, 7 août 1909, *Winkell* et *Rosier*, n° 37317 (Deux espèces). Faits : près de six cents agents grévistes de l'administration des postes avaient été révoqués. Hauriou remarque placidement : « Ils ont commis des faits de guerre, donc on ne s'étonnera pas que le gouvernement leur ait appliqué le droit de la guerre.[3] »

➢ Autres temps, autres règles. Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dispose : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » Le Conseil d'État révise alors sa jurisprudence : CE, Ass., 7 juillet 1950, *Dehaene*, n° 01645. Dans cette affaire, le commissaire du gouvernement Gazier affirme : « La grève des boulangers et celle des laitiers affectent plus la vie de la Nation que celle des gardiens de musée ou des conservateurs d'hypothèques ». Toutefois, poursuit-il, « admettre sans restriction la grève des fonctionnaires, ce serait ouvrir des parenthèses dans la vie constitutionnelle, consacrer officiellement la notion d'État à éclipses. »

En conséquence, le principe de continuité

- prive certains fonctionnaires du droit de grève,
- impose, dans certains (rares) cas de grève, l'organisation d'un service minimum : par, exemple, en cas de grève dans l'audiovisuel public ou dans les hôpitaux publics.

*****Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions*****
[DÉBUT]

► Une évolution se dessine

- avec le code de l'Éducation (rédaction issue de la *loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire*) Est prévu

---

[1] CE, 29 juillet 2002, *Centre hospitalier d'Armentières*, n° 243500 : « Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle ; qu'en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant de l'administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ; qu'en cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ; ». Voir aussi CE Sect. 13 juillet 1956, *OPHLM du département de la Seine*, n° 37656 ; CE 1er mars 2012, *Société assistance conseil informatique professionnelle*, n° 354628.

[2] Le mot désignait la place de Paris où se rassemblaient les travailleurs en quête d'ouvrage.

[3] Note sous l'arrêt précité. Surprenant doyen : après avoir fustigé l'amour, il magnifie la guerre !

l'institution d'un service minimum d'accueil, qui correspond à l'engagement pris par des communes, dans une convention conclue avec l'État, d'accueillir les enfants, les jours de grève, pendant les heures habituelles d'enseignement (Article L133-1 du code de l'Éducation) ;

▪ et avec le code des transports (aériens et terrestres), dans sa rédaction issue notamment de la *loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports* ainsi que de *l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010*. Les articles L1114-3 et L1324-7 de ce code imposent, dans le cadre d'un plan de prévisibilité, aux salariés d'informer le chef d'entreprise de leur intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant le déclenchement du mouvement.

► Par ailleurs, s'agissant des modalités concrètes et des conséquences de l'exercice du droit de grève, deux observations :

1. d'une part, la loi impose le dépôt d'un préavis de cinq jours francs avant le déclenchement d'une grève dans un service public. Ce préavis émane des organisations syndicales représentatives. Il indique le lieu, les motifs, la date et la durée limitée ou illimitée de la grève ;

2. d'autre part, la loi permet d'opérer des **retenues sur les traitements** des grévistes soit selon une certaine proportionnalité - fonctions publiques hospitalière et territoriale - soit en vertu de la règle du *trentième indivisible* - dans la fonction publique de l'État. Signification de la règle : quelle que soit la durée quotidienne de la grève, le chef de service peut opérer une retenue égale au trentième du traitement de l'agent gréviste – CE, 7 juillet 1978, *Omont*, n° 03918[1]. Les retenues opérées ne sont pas des sanctions disciplinaires[2] ; elles sont simplement la conséquence de la règle du traitement après service fait.

[/FIN]

**

2 - Le principe d'adaptation ou de mutabilité

Raison d'être et définition du principe de mutabilité

► *Si un besoin d'intérêt général est souvent continu, il est rarement invariable. Le service public doit donc s'adapter aux variations de l'intérêt général*.

Cette adaptation est le fait de la personne en charge du service public.

✓ **Définition :** le **principe d'adaptation ou de mutabilité** du service public, c'est le principe (ou la règle) en vertu duquel la personne en charge d'un service public peut et, parfois, doit modifier ses règles d'organisation ou de fonctionnement en vue de le rendre plus efficace ou plus attractif.

---

[1] CE, 7 juillet 1978, *M. Omont*, n° 03918. Le Conseil d'État juge « qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ». Exemple : un agent se met en grève un vendredi et reprend le travail le lundi après-midi. Le décompte sera le suivant : du vendredi au lundi, il y a 4 jours (samedi et dimanche compris). L'agent se verra retenir 4/30èmes de sa rémunération pour fait de grève

[2] Il est facile de le démontrer :
- il n'y a pas de sanction sans texte - *nulla poena sine lege*,
- les retenues pour exercice du droit de grève ne figurent pas dans la liste - exhaustive - des sanctions disciplinaires.
Mais bien entendu, rien n'empêche l'agent concerné de percevoir l'opération comme une sanction - sur cette contradiction entre la réalité juridique et le vécu personnel, cf. infra *Police administrative*.

Conséquences découlant du principe de mutabilité

► Le principe d'adaptation ou de mutabilité emporte des conséquences :

1. Conséquences vis-à-vis du personnel. Les agents du service public ne peuvent faire obstacle, pour le principe, à la modification de son organisation ou de son fonctionnement. L'invocation de droits acquis serait inopérante - théorie et réalité des grèves ;

2. Conséquences vis-à-vis des usagers. Ces derniers ne peuvent invoquer des droits acquis, des intérêts particuliers, à l'encontre des changements apportés à l'organisation ou au fonctionnement du service public. Leurs droits procèdent en grande partie des dispositions régissant le service. Mais ces dispositions peuvent être modifiées unilatéralement, c'est-à-dire sans leur consentement, par l'administration - au nom de l'intérêt général.

Par ailleurs, rappelons que, selon le Conseil d'État, « les usagers d'un service public qui n'est pas obligatoire n'ont aucun droit au maintien de ce service au fonctionnement duquel l'administration peut mettre fin lorsqu'elle l'estime nécessaire » - CE, Sect., 18 mars 1977, *Chambre de commerce de la Rochelle*, n° 97939. En effet, l'administration a toujours la faculté de mettre fin à un service public, sauf si la loi a rendu obligatoire ce service : CE, Sect., 27 janvier 1961, *Vannier* - à propos de la cessation des émissions de télévision sur la définition des 441 lignes de la télévision - ; CE, 16 janvier 1991, *Fédération nationale des associations d'usagers des transports*, n° 116212 116224 – décision admettant la légalité de la suppression, en raison de la très faible fréquentation, d'une desserte ferroviaire dans le Massif Central ;

3. Conséquences vis-à-vis de l'administration et de ses cocontractants. L'autorité administrative doit prendre des mesures d'adaptation du service public afin d'assurer un accès « normal » de l'usager au service public, mais elle ne saurait adapter le service public de telle sorte que soit compromis cet accès « normal » - CE, 25 juin 1969, *Vincent*, n° 69449[1]. Qui plus est, l'administration ne peut pas renoncer, pour l'avenir, à créer ou à supprimer un service public[2].

Les relations contractuelles sont également affectées par le principe de mutabilité. Par exemple, l'administration concède un service public à un particulier. Le contrat qui les lie définit les modalités de fonctionnement du service public. En cours d'exécution, l'administration a le droit de modifier unilatéralement ce contrat et donc les modalités de fonctionnement du service public - *Cf.* CHAPITRE II – SECTION II, Les c*ontrats administratifs*.

► Le principe de mutabilité comporte tout de même des limites :

- Les modifications doivent être inspirées par le souci de l'intérêt général ;
- Elles ne doivent pas compromettre l'accès « normal » au service public - CE, 25 juin 1969, *Vincent*, n° 69449 ;
- Les changements ne valent que pour l'avenir. Ils ne sauraient rétroagir : CE, Ass., 25 juin 1948, *Société du journal l'Aurore*, n° 94511 ;
- Si l'administration veut modifier le fonctionnement du service public, elle doit, au préalable, modifier les règles qui le gouvernent. Tant qu'elles n'auront pas été modifiées, le service public doit fonctionner conformément à ces règles - CE, 27 janvier 1988, *Giraud*, n° 64076.

**

[1] CE, 25 juin 1969, *Vincent*, n° 69449 : « Considérant que le refus du ministre de modifier par les décisions attaquées les heures d'ouverture du bureau de poste d'Ermont était fondé sur ce que la situation particulière de ce bureau ne justifiait pas une dérogation aux règles générales qu'il avait fixées pour l'ouverture des bureaux de poste ; qu'il ne résulte des pièces du dossier, ni que les faits servant de base aux décisions précitées soient matériellement inexacts, ni que l'application, dans la commune en cause, des horaires ainsi fixés ait eu pour effet de limiter dans des conditions anormales le droit d'accès des usagers au service public postal ; »

[2] CE, 9 mars 1951, *Ville de Villefranche-sur-Saône*, Rec. p. 144.

3 - Le principe d'égalité

Raison d'être, définition et portée du principe d'égalité

Il découle du principe d'égalité devant la loi[1]. Il comporte un certain nombre de corollaires.

a - La portée du principe

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Question initiale :

► Quelle est la signification du principe d'égalité ?

Réponse soutenue et développée dans ce cours :

➢ Le principe d'égalité signifie

1. que normalement, c'est-à-dire en principe, l'administration **doit** traiter d'une *manière identique* les usagers du service public,

2. que, dans certains cas, l'administration **peut** *traiter différemment* les usagers du service public,

3. mais que, sauf disposition législative contraire, l'administration **n'est obligée** de traiter différemment des usagers se trouvant dans des situations différentes - CE, Ass., 28 mars 1997, *Société Baxter et autres*, n° 179049, 179050 et 179054.

↓ Développement ↓

✓ **Définition :** le **principe d'égalité devant le service public**, c'est le principe (ou la règle) selon lequel la personne en charge d'un service public doit traiter d'une manière identique les usagers de ce service public.

► Le Conseil constitutionnel

▪ a indiqué le **fondement constitutionnel** du principe d'égalité devant le service public : « [Ce] principe résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »[2].

▪ non sans l'avoir rangé d'abord parmi les « principes fondamentaux du service public »[3], moyennant un assouplissement inspiré de la jurisprudence du Conseil d'État : « [S]i le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions

---

[1] Égalité devant la loi, dans la loi ou par la loi ?
Dans le premier cas (égalité devant la loi), la manière d'appliquer la loi est la même pour tous.
Dans le deuxième cas (égalité dans la loi), le contenu de la loi est le même pour tous.
Enfin, dans le troisième cas (égalité par la loi), le contenu de la loi est voulu inégal pour pallier les inégalités de fait.

[2] Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, *Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires*.

[3] Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, *Loi relative à la liberté de communication.*

différentes […] » - Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, *Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales*.

► Quant au Conseil d'État, il a reconnu le principe d'égalité devant le service public

▪ d'abord, **implicitement** : CE, 29 décembre 1911, *Chomel*, Rec. 1265 ;

▪ puis, **explicitement** : CE, 10 février 1928, *Chambre syndicale des propriétaires marseillais*, Rec. 222 ; CE, 6 mai 1931, *Tondut*, Rec. 477 ;

▪ et, enfin, en tant que **principe général du droit** conduisant à l'annulation des différences de traitement injustifiées entre usagers du service public : CE, Ass., 1er avril 1938, *Société L'Alcool dénaturé de Coubert et sieurs Legrand et autres*, n° 54715-54825, Rec. 337 ; CE, Sect., 9 mars 1951, ***Société des concerts du conservatoire***, n° 92004.

Le Conseil d'État a également défini la portée du principe d'égalité.

➢ **Le principe d'égalité n'impose pas *inconditionnellement* à l'administration de traiter d'une manière identique tous les usagers du service public**.

✓ ***Exemple*** : CE, Sect., 10 mai 1974, *Denoyez et Chorques*, n° 88032 88148.

Un bac assure la liaison entre le continent et l'île de Ré.

Le principe d'égalité permet-il l'octroi de tarifs réduits aux seuls habitants de l'île de Ré ?

Réponse du Conseil d'État : « La fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la **conséquence nécessaire d'une loi**, soit qu'existent entre les usagers des **différences de situations appréciables**, soit qu'une **nécessité d'intérêt général** en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure. »

Dans l'espèce précitée, la mesure était **légale** en raison des **différences de situations** existant entre les habitants de l'île de Ré et les autres usagers.

Les trois cas dans lesquels un traitement différencié est possible sans qu'il en résulte une violation du principe d'égalité

► Normalement, un traitement identique des usagers s'impose.

► Un traitement différencié n'est légal que s'il a l'un des trois fondements suivants :

1. **la loi**,
2. **des différences de situation**
3. ou **une nécessité d'intérêt général liée au service public.**

Analysons chacun de ces trois fondements possibles.

▪ **1er fondement possible à un traitement différencié :** ***la loi***. Un traitement différencié est justifié s'il est la conséquence nécessaire d'une loi, s'il est prévu par une disposition législative ;

▪ **2e fondement possible à un traitement différencié :** ***des différences de situation***. L'objectif visé ici est d'éviter ce que l'on appelle les « **discriminations indirectes** ». La notion de discrimination indirecte « désigne les situations où le respect de l'égalité formelle, appliqué à des situations trop hétérogènes, non seulement ne suffit pas à prévenir la discrimination, mais d'une certaine façon la caractérise ». Elle trouve son origine dans la jurisprudence de la CJCE, qui observait dans l'un de ses premiers arrêts : « [L]a discrimination consiste non seulement à traiter de manière différente des situations semblables, mais aussi à traiter de manière identique des situations différentes » -

17 juillet 1963, Gouvernement de la République italienne c/ Commission, affaire 13-63, recueil CJCE p. 341.

Quatre précisions (**a, b, c** et **d**) permettront de saisir les différences de situation en tant que deuxième fondement possible à un traitement différencié.

a. Pour justifier un traitement différencié, les différences de situation existant entre les usagers doivent être **appréciables**, **objectives** et **en rapport avec l'objet du service public**. L'égalité de traitement n'a de valeur que si les usagers se trouvent dans des situations comparables au regard de l'objet du service public. Parfois, un traitement identique équivaut à un traitement inique. À situations différentes, traitements différents à condition que les différences de situation revêtent les caractères ci-dessus énumérés.

✓ ***Exemple*** : CE, Ass., 6 avril 2001, *M. Pelletier et autres*, n° 224945 :

> « [Considérant que] les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; […] ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître ni le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'occupation comme placés dans une **situation différente** de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ;»

b. Comme les différences de situation, **la différence de traitement décidée par l'administration doit avoir un rapport avec l'objet du service public** – CE, Sect., 25 juillet 2007, *Syndicat des avocats de France*, n° 288720.

c. Qui plus est, pour éviter que ceux qui se trouvent dans une situation différente ne soient ni trop avantagés ni, au contraire, trop désavantagés, **la différence de traitement ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier** : CE, Sect., 18 décembre 2002, *Mme Duvignères*, n° 233618 ; CE, Ass., 28 juin 2002, *Villemain*, n° 220361 ; CE, Sect., 25 juillet 2007, *Syndicat des avocats de France*, n° 288720.

d. L'administration n'a pas l'obligation de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Certes, comme nous l'avons vu, **l'administration a le droit** de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Mais il faut savoir que, selon le Conseil d'État, **elle n'en a pas l'obligation** : CE, Ass., 28 mars 1997, *Société Baxter et autres*, n° 179049[1]. En d'autres termes, vous ne pouvez pas exiger de l'administration qu'elle vous traite différemment au motif que votre situation serait différente de celle des autres.

Cette position du juge administratif a été adoptée par le Conseil constitutionnel : « [Considérant] que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; » - Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004.

▪ **3e fondement possible à un traitement différencié :** ***une nécessité d'intérêt général liée au service public***. Ce fondement apparaît comme **subsidiaire**. Avant d'y recourir, le juge s'assure d'abord de l'inexistence des autres fondements. Il vérifie également que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet du service public et ne soit pas manifestement disproportionnée.

✓ ***Exemple*** : CE, Sect., 11 juillet 2001, *Syndicat départemental CFDT de la direction départementale de l'équipement du Gard*, n° 220062 :

[1] Cette solution est également énoncée dans la décision CE, 22 mars 1950, *Société des ciments français*, (n°s 87957 et 87958, Rec. 175) qui juge que l'administration ne viole pas l'égalité de traitement des producteurs d'une même catégorie, ayant des coûts d'exploitation différents, en leur imposant un prix unique.

> « [E]u égard à **l'intérêt général** qui s'attache à ce que les agents publics soient répartis sur le territoire en fonction des besoins de la population et des nécessités du service, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, prévoir que le montant de "l'indemnité spécifique de service" - qui est distincte du traitement - varierait selon les départements et chercher ainsi à remédier par cette incitation financière aux déséquilibres constatés dans les demandes d'affectation et les vacances d'emplois ; »

*****Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions***** [DÉBUT]

► **Au regard de ces principes, le Conseil d'État a jugé non contraires au principe d'égalité :**

1. le fait, vu l'afflux des demandes, de réserver l'accès à un service public municipal aux usagers qui ont un lien particulier - en fait fiscal - avec la commune - CE, Sect., 13 mai 1994, *Commune de Dreux, n° 116549*, Rec. p. 233 ; RFDA 1994 p. 711, conclusions Daël). Dans ce cas, une différence de situation justifie le traitement différencié ;

2. la fixation de tarifs différents

▪ selon que les usagers sont ou non domiciliés dans la commune, pour l'accès aux cantines scolaires - CE, Sect., 5 octobre 1984, *Commissaire de la République du département de l'Ariège c/ Commune de Lavelanet*, n° 47875, (Rec. p. 315, conclusions Delon) - ou aux écoles de musique - CE, 2 décembre 1987, *Commune de Romainville*, n° 71028, (Rec. tables p. 631 ; RFDA 1988 p. 414, conclusions Massot). Les différences de situation fondent ces traitements différenciés ;

▪ selon les ressources des familles, pour l'accès aux écoles de musique municipales - CE, Sect. 29 décembre 1997, deux espèces : *Commune de Gennevilliers*, n° 157425 ; *Commune de Nanterre*, n° 157500, (RFDA 1998 p. 539, conclusions J.-H. Stahl). Ici, le Conseil d'État justifie les traitements différenciés en retenant une nécessité d'intérêt général : la possibilité que tous les élèves puissent fréquenter les écoles de musique municipales. Un terme est ainsi mis à la jurisprudence issue de la décision CE, Sect., 26 avril 1985, *Ville de Tarbes*, n° 41169, (Rec. p. 119, conclusions contraires de Lasserre).

▪ **Ces solutions s'expliquent mieux à la lumière de trois observations :**

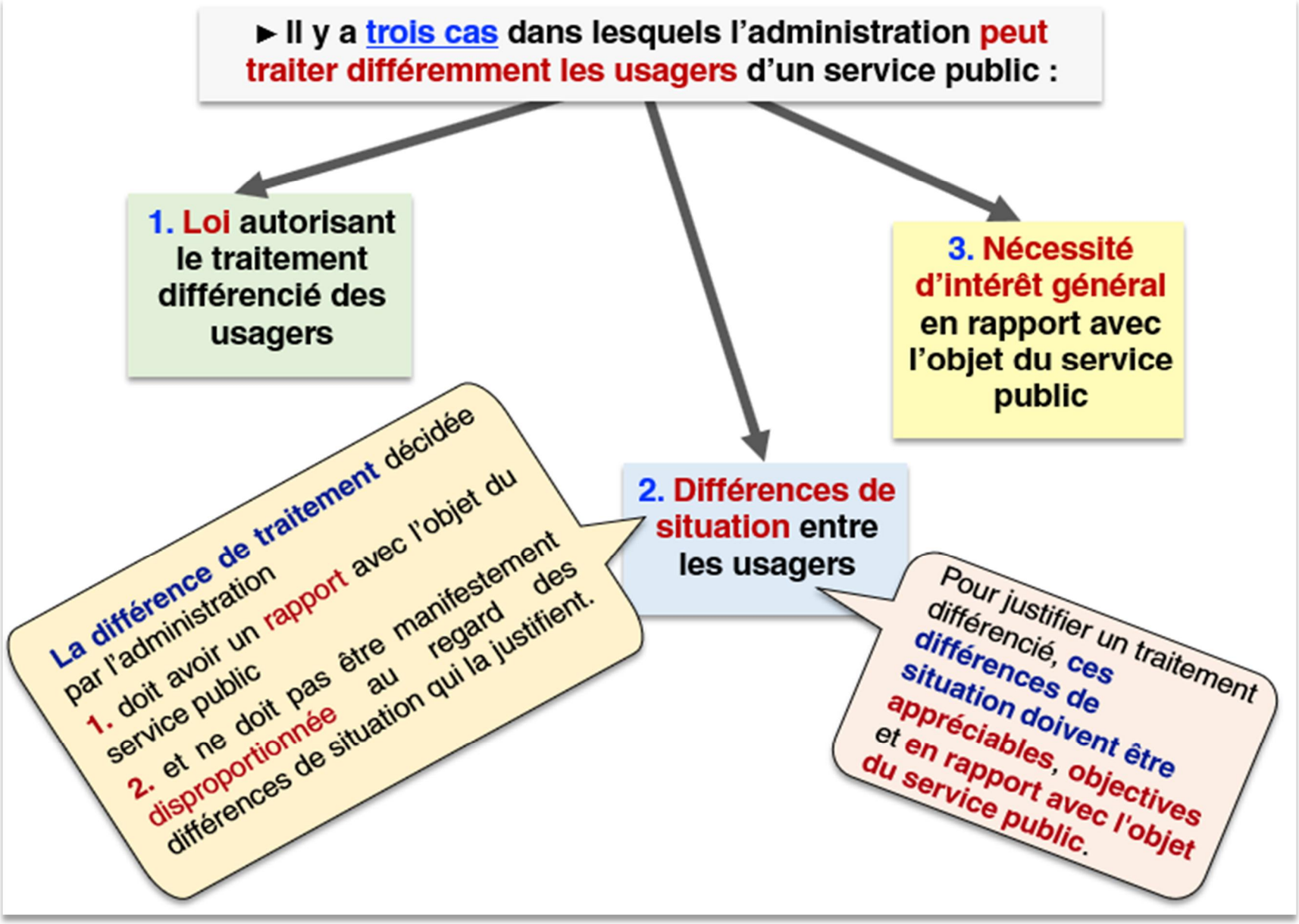
1. il s'agit de services publics à caractère administratif,

2. ce ne sont pas des services publics obligatoires, la loi n'imposant pas aux communes de les créer,

3. les tarifs les plus élevés restent inférieurs au coût réel de ces services publics, que les communes subventionnent donc largement. Voir *a contrario* CE, 2 avril 1997, *Commune de Montgeron,* n° 124883 : illégalité des tarifs les plus élevés car ils excédaient le prix de revient du service fourni.

[/FIN]

***


► Il y a trois cas dans lesquels l'administration peut traiter différemment les usagers d'un service public :
1. Loi autorisant le traitement différencié des usagers
2. Différences de situation entre les usagers
3. Nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet du service public
La différence de traitement décidée par l'administration
1. doit avoir un rapport avec l'objet du service public
2. et ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des différences de situation qui la justifient.
Pour justifier un traitement différencié, ces différences de situation doivent être appréciables, objectives et en rapport avec l'objet du service public.

b - Les corollaires du principe

i - L'égal accès aux emplois publics

► Il est proclamé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tous les citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité ; et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

► Le principe de l'égal accès aux emplois publics fait obstacle aux discriminations, mais s'accommode de quelques dérogations.

*****Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions***** [DÉBUT]

➢ **Le principe de l'égal accès aux emplois publics s'oppose aux *discriminations fondées sur les opinions politiques ou religieuses*** : CE, Ass., 28 mai 1954, *Barel et autres*, n° 28238, 28493, 28524, 30237 et 30256, (Rec. p. 308). Contexte : la guerre froide bat son plein, le maccarthysme, véritable « chasse aux sorcières communistes », sévit aux États-Unis. En France se pose la question de l'admission des communistes à l'ENA. Le secrétaire d'État à la Fonction publique croit pouvoir et devoir répondre par la négative[1]. Le Conseil d'État censure sa décision au nom du principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics - position contraire à celle adoptée en 1952 par la Cour constitutionnelle allemande.

On peut estimer que le juge a établi… sa religion, en la matière, par l'arrêt CE 10 mai 1912, *Abbé Bouteyre*, n° 46027 (Rec. 553).

Faits et solution de l'espèce :

Un abbé souhaite s'inscrire sur la liste des candidats au concours d'agrégation de philosophie de l'enseignement secondaire.

Réponse indirecte et négative du ministre de l'instruction publique : « L'état ecclésiastique auquel il s'était consacré s'oppose à ce qu'il soit admis dans le personnel de l'enseignement public, dont le caractère est la laïcité. Par suite, il n'y a pas lieu de l'autoriser à prendre part aux épreuves. »

Le Conseil d'État rejette le recours pour excès de pouvoir formé par l'abbé. Motif : dans l'intérêt du service, le ministre n'a fait qu'user, à l'égard du candidat, de son droit d'appréciation.

Explication du commissaire du gouvernement Helbronner : « L'État a le droit de s'assurer que le candidat à une fonction ne se trouve pas dans le cas de ne pas la remplir selon l'esprit et le but en vue desquels la loi l'a instituée. » Un tel pouvoir d'appréciation découle d'un texte exprès - c'est le cas en l'espèce - ou d'un principe général - la bonne marche du service.

Démarche à suivre par l'autorité compétente : l'autorité administrative ne doit pas se baser sur les idées présumées, les opinions politiques ou religieuses des candidats. Ce serait une atteinte inadmissible à la liberté des citoyens. Mais il arrive que les opinions se manifestent avant la candidature par un acte public qui, par sa nature, serait incompatible avec l'exercice des fonctions sollicitées[2]. L'autorité administrative pourra écarter, pour ce motif, le candidat concerné.

Jean Rivero dénonce : « On redouterait fort une administration dont tous les membres, ayant précédemment rêvé de l'État, auraient observé durant toute leur jeunesse, dans l'expression de leurs opinions, la réserve qui sied au haut fonctionnaire. Il serait à craindre que les hommes de caractère y fussent rares. »[3]

➢ **Le principe de l'égal accès aux emplois publics s'oppose aussi aux *discriminations fondées sur le sexe.***

Aujourd'hui, l'égalité des sexes dans l'accès à la fonction publique semble juridiquement bien établie.

Cette égalité résulte d'une **évolution en trois temps**, sachant que les femmes n'ont jamais été exclues d'une manière générale de la fonction publique.

---

[1] Raymond Aaron publie un article intitulé *Le communisme n'est pas une opinion*.

[2] *A contrario*, comment tenir compte d'une opinion inexprimée ?

[3] *L'obligation de réserve*, AJDA 1977, p. 580.

▪ **1er temps** : CE, Ass., 3 juillet 1936, *Dlle Bobard et autres* (Rec. p. 721). Le décret du 15 août 1934 réserve au personnel masculin l'accès aux emplois de rédacteurs et à ceux d'un grade supérieur du ministère de la guerre. Quarante femmes et la demoiselle Bobard attaquent immédiatement ce décret. Le Conseil d'État juge d'abord que « les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des administrations centrales des ministères ». Mais il ajoute : « Il appartient au gouvernement de décider si des *raisons de service* nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l'admission et à l'avancement du personnel féminin. » L'appréciation faite par le gouvernement est insusceptible de discussion contentieuse ;

▪ **2e temps** : Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dispose : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. »

Le Conseil d'État reconnaît alors le principe de l'égalité des sexes devant les emplois publics : CE, Ass., 6 janvier 1956, *Syndicat national autonome du cadre d'administration générale des colonies* (Rec. 4). Mais il admet des dérogations à ce principe « dans le cas où la *nature des fonctions* exercées ou les *conditions d'exercice* de ces fonctions exigent de telles dérogations ».

L'appréciation faite par le gouvernement est susceptible de discussion contentieuse.

La formule jurisprudentielle est reprise par la loi du 10 juillet 1975. Son apport : les exceptions peuvent jouer dans les deux sens. Il peut légalement exister des corps à recrutement exclusivement masculin ou féminin - discrimination égalitaire ;

▪ **3e temps** : Le droit communautaire fixe comme objectif aux États membres la mixité de tous les corps de fonctionnaires - directive du 9 février 1976. Dans un avis du 25 avril 1981, la Commission estime que la France méconnaît cette directive.

Après la loi du 7 mai 1982, le statut général pose le principe de la mixité des corps. Il écarte la possibilité de recrutements exclusifs d'hommes ou de femmes. Mais il admet la possibilité, pour certains corps, d'organiser des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions. Des concours communs peuvent également comporter quelques épreuves distinctes - épreuves physiques, essentiellement, bien entendu.

La liste des corps à recrutement distinct est fixée par le décret du 3 mars 1992 : corps des attachés des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire.

✓ ***Exemple*** : CE, 11 mai 1998, *Mlle Aldige*, n° 185049. L'article 2 du décret du 12 mars 1984 dispose : « En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps des commissaires de l'armée de terre, l'accès des femmes à ce corps est limité à 20 % du recrutement annuel. » Le Conseil d'État estime néanmoins qu'une telle dérogation au principe d'égal accès aux emplois publics n'est justifiée ni par la nature des fonctions de commissaire de l'armée de terre, ni par les conditions particulières dans lesquelles ces fonctions sont exercées.

Évidemment, il arrive qu'une autorité misogyne pose (illégalement ou non) des conditions que les femmes remplissent rarement : taille, poids etc.

[/FIN]

***

ii - La neutralité et la laïcité

Résumé et intérêt de cette partie du cours

Questions initiales :

1. En quoi la neutralité et la laïcité constituent-elles des corollaires du principe d'égalité ?
2. Les élèves peuvent-ils porter des signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires ?

Réponses soutenues et développées dans ce cours :

1. En quoi la neutralité et la laïcité constituent-elles des corollaires du principe d'égalité ?

2. Ne pas être laïque, c'est ne pas rester neutre du point de vue religieux, et ne pas rester neutre, c'est prendre parti. Or, prendre parti, c'est nécessairement prendre parti ***pour*** et, explicitement ou implicitement, prendre parti ***contre*** ; c'est se préparer *ipso facto* à favoriser les uns au détriment des autres, et donc à rompre l'égalité.

3. Les élèves peuvent-ils porter des signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires ?

L'article L. 141-5-1 du code de l'Éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, les signes et tenues ostensibles, c'est-à-dire « ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ».

Ces dispositions ne remettent pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.

↓ Développement ↓

► Au plan théorique, la laïcité à la française a une signification relativement précise :

- la religion relève de la sphère privée ;
- les pouvoirs publics doivent affirmer et préserver leur indépendance et leur neutralité à l'égard des institutions religieuses.

En pratique, la liberté de religion (ou liberté religieuse) comporte deux dimensions :

- la liberté de croire ou de ne pas croire ;
- le droit d'exprimer, de manifester ses convictions religieuses, notamment par l'exercice d'un culte.

Ainsi entendue, la liberté de religion est garantie par de nombreux textes, tant internes qu'internationaux, qui en font une composante de la liberté de pensée ou de conscience.

L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »

Dans le même sens, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme stipule en son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »

*

► **S'agissant de la laïcité et de la neutralité de l'État, un bref rappel historique s'impose.**

Jusqu'en 1905, les rapports entre les Églises et l'État étaient régis par le Concordat conclu entre Napoléon Ier et le pape Pie VII en 1801.

L'élément saillant de ces rapports, c'était la reconnaissance des cultes : la religion catholique (qualifiée de « religion de la majorité des Français ») ainsi que les cultes réformé, calviniste et israélite. En plus d'être reconnus officiellement, ces quatre cultes étaient érigés en services publics.

La loi du 9 décembre 1905, dite de séparation des Églises et de l'État, abolit ce régime (sauf dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) et proclame la neutralité de l'État en matière religieuse. Elle dispose en son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…). »

La loi de 1905 ne se borne pas à consacrer l'indifférence de l'État à l'égard du fait religieux ; elle lui impose également de garantir l'effectivité de la liberté de culte. L'article 1er de cette loi dispose ainsi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »[1]

Ainsi donc, la loi de 1905 « crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. » - CE, Avis contentieux, 28 juillet 2017, *M. A.*, n° 408920.

L'obligation de neutralité et de laïcité de l'État (et, partant, des services publics) figure aussi à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

➢ De son côté, le Conseil d'État considère que la laïcité est un principe fondamental reconnu par les lois de la République - CE, 6 avril 2001, *Syndicat national des enseignants du second degré* (SNES), n° 219379.

► **Il incombe au juge** (administratif ou judiciaire) **de garantir la conciliation entre, d'une part, l'intérêt général ainsi que l'ordre public et, d'autre part, la liberté de religion et son expression.**

L'autorité administrative peut limiter ou interdire toute expression de la liberté religieuse qui porte atteinte à l'ordre public ou à l'intérêt général.

➢ Selon la Cour de cassation, « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé » - Cass., soc., 19 mars 2013, *Mme X. c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et autres*, n° 12-11690. Toutefois, « le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public » - Cass., soc., 19 mars 2013, *Mme Fatima X., épouse Y. c/ Association Baby Loup*, n° 11-28845.

➢ La neutralité s'impose d'abord à la personne qui gère le service public ; cette personne ne saurait se servir du service public pour promouvoir ses idées, pour défendre certains intérêts au détriment d'autres. Elle ne saurait non plus apposer sur les édifices publics, et notamment sur les mairies, des signes manifestant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques (CE, 27 juillet 2005, *Commune de Sainte-Anne*, n° 259806)

---

[1] CE, Avis contentieux, 28 juillet 2017, *M. A.*, n° 408920 : Une croix sur le portail d'un cimetière peut y demeurer, être entretenue, restaurée et remplacée si son installation est antérieure à la loi du 9 décembre 1905 dont l'article 28 a eu pour objet d'affirmer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes.

➢ La neutralité s'impose également aux agents du service public : CE, 19 mars 1997, *M. Cannard*, n° 133338, (contrôleur divisionnaire des fraudes faisant de la publicité pour certains des professionnels qu'il surveillait).

➢ On trouve à l'article L141-6 du code l'Éducation une affirmation de principe : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »

*

► La laïcité, qui ne concerne que les rapports entre les collectivités publiques et les individus, s'accommode-t-elle du port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics ?

1. Réponse en ce qui concerne les élèves

► Elle résulte d'un texte à l'intitulé on ne peut plus parlant : loi **n° 2004-228 du 15 mars 2004** *encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*.

➢ L'article premier de cette loi du 15 mars 2004 (devenu l'article L141-5-1 du code de l'éducation) dispose :

« **Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.**

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »

➢ En 2007, sur le fondement de ces dispositions législatives, le Conseil d'État juge

▪ que, les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets,

▪ mais qu'en revanche sont interdits : d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse ; d'autre part, les signes dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève,

▪ et qu'ainsi le « keshi » sikh (« sous-turban »), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et que le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte (CE, 5 décembre 2007, *M. Shain*, n° 285394).

❖ **Nota bene :** Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement supérieur ; il serait donc illégal, en l'état actuel du droit, d'exclure des étudiantes, motif pris de ce que les intéressées portent un voile à caractère religieux – CE, 26 juillet 1996, *Université de Lille II*, n°170106.

C'est ainsi que le Conseil d'État juge que les élèves infirmiers (enseignement supérieur) tout comme les autres étudiants sont libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par leurs vêtements ou le port de signes religieux, mais lorsqu'ils effectuent un stage dans un hôpital public, l'obligation de laïcité s'impose à eux - CE, 28 juillet, 2017, *Mme A et autres*, n° 390740.

2. Réponse en ce qui concerne les agents (professeurs, etc.)

► Qu'ils soient ou non chargés de fonctions d'enseignement, « le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. » (CE, Avis du 3 mai 2000, *Mlle Marteaux*, n° 217017).

➢ La solution vaut également pour les agents des autres services publics :

▪ Ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leurs croyances ;

▪ Mais ils n'ont pas le droit de manifester leurs croyances dans le cadre du service public, de quelque manière que ce soit (pas de port de signes ***visibles*** d'appartenance religieuse, par exemple).

Par exemple, **un fonctionnaire, qu'il soit un enseignant ou non, n'a pas le droit de porter sur son lieu de travail un signe d'appartenance religieuse même discret**.

► Les principes de neutralité et de laïcité pèsent donc plus sur les agents que sur les usagers.

➢ Ce traitement inégal s'explique aisément : parce qu'il a la charge de la mise en œuvre du principe d'égalité devant le service public, « l'agent ne doit pas, par son comportement, autoriser un quelconque doute sur la neutralité du service public ».

Malgré la rigueur du principe, un fonctionnaire peut bénéficier d'une autorisation d'absence pour participer à une fête religieuse - CE, 12 février 1997, *Mlle Henny*, n° 125893.

3. Réponse en ce qui concerne les autres usagers (parents, etc.)

L'article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, entrée en vigueur, pour l'essentiel, le 11 avril 2011, dispose :

« Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »

Par **« espace public »,** il faut entendre, aux termes de l'article 2,

▪ **les voies publiques.** Interprétation donnée par le Premier ministre dans une circulaire du 2 mars 2011 : « Il convient de préciser qu'à l'exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique. »[1]

▪ **les lieux ouverts au public.** La circulaire précitée souligne : « Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics. »

▪ **les lieux affectés à un service public.** Dans la même circulaire, on lit : « Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les

[1] Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.

bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques. »

L'article 3 de la loi du 11 octobre 2010 prévoit que la méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie d'une amende d'un montant maximal de 150 euros.

L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée à titre de peine alternative ou de peine complémentaire.

L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du visage :

- tenue prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires. ***Exemple*** : le port du casque par les conducteurs de deux-roues à moteur ;
- tenue justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels ou sportifs, etc.

*****Développements additionnels utiles** (TD, concours, etc.) **mais exclus des révisions***** [DÉBUT]

La solution retenue actuellement pour les élèves est l'aboutissement d'une évolution qu'il convient de décrire en exposant successivement

I. les données juridiques de base du problème

II. et les avatars de la conciliation qui en a été faite.

I. *<u>Les données juridiques de base du problème</u>* (elles paraissent contradictoires) **:**

1. *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 10* : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » [Aucune liberté n'est absolue] ;

2. *Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire*,

Article 2 : « Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'**instruction religieuse en dehors des édifices scolaires**. »

Article 4 : « **L'instruction primaire est obligatoire** pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. »

3. *Loi du 30 octobre 1886, relative à l'enseignement primaire* : « Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel **laïque** ».

4. *Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État, article 2* : « **La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.** »

Pour Hauriou, c'est une « fiction d'ignorance légale ». La République ne reconnaît aucun culte, mais elle les connaît tous - laïcité oblige[1] ;

5. Constitution du 27 octobre 1946, préambule : « L'organisation de l'**enseignement laïque** et gratuit à tous les degrés est un devoir de l'État. » ;

6. *Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 9* : « **Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de**

[1] Cependant, le respect dû à la liberté religieuse impose à l'État non seulement des obligations négatives - abstention, neutralité - mais aussi des obligations positives. Ainsi, le Conseil d'État a-t-il pu retenir à la charge de l'autorité administrative l'obligation de prendre des mesures indispensables pour permettre l'exercice du culte, en réservant un local à cet effet à l'intérieur d'un hôpital - CE, Sect., 28 janvier 1955, *Aubrun*, Rec. p.50.

religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la **liberté de manifester sa religion ou sa conviction** individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

7. *Constitution du 4 octobre 1958, article 1er* : « La France est une République indivisible, **laïque**, démocratique et sociale […] Elle respecte toutes les croyances. »

8. *Loi d'orientation sur l'Éducation du 10 juillet 1989, article 10* : « Dans les **collèges** et les **lycées**, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité de la liberté d'information et de la **liberté d'expression** ».

II. *La conciliation des données juridiques de base du problème* :

1. L'ancienne solution jurisprudentielle

► Les règles de l'ancienne solution jurisprudentielle avaient été exposées pour la première fois dans l'avis rendu par le Conseil d'État le 27 novembre 1989.

Elles avaient ensuite été confirmées au contentieux, à l'occasion d'affaires plus ou moins médiatisées (au total une vingtaine d'arrêts).

➢ Le principe qui dominait ces règles était le suivant : il était interdit d'interdire, par principe, le port de signes d'appartenance religieuse. Un élève ne pouvait être sanctionné au seul motif qu'il aurait porté un signe religieux.

➢ **En fait, on peut résumer l'ancienne solution jurisprudentielle de la manière suivante :**

a. Le port de signes d'appartenance religieuse était permis : « Les élèves ont le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires. »

b. Mais l'exercice de ce droit comportait des restrictions :

- il ne devait pas faire obstacle ni porter atteinte aux activités d'enseignement ;
- il ne devait pas porter atteinte à la sécurité ou à la dignité des intéressés, encore moins à l'ordre public au sein des établissements ;
- le port de signes d'appartenance religieuse ne devait ni revêtir un caractère **ostentatoire** ni constituer un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande.

Le juge tenait pour illégaux les règlements intérieurs des établissements scolaires qui interdisaient d'une manière générale et absolue le port de signes d'appartenance religieuse : CE, 2 novembre 1992, *Kherouaa, Kachour, Balo et Kizic*[1], n° 130394, (Rec. 389).

Il fallait apprécier au cas par cas avec les risques d'arbitraire qu'un tel procédé impliquait.

► À l'usage, cette jurisprudence s'est révélée très délicate à mettre en œuvre : comment, par exemple, faire le départ entre un signe ostentatoire et un signe qui ne serait pas ostentatoire ?

C'est pourquoi des voix ont appelé de leurs vœux l'adoption d'une loi.

[1] Cf. aussi CE, 10 mars 1995, *Époux Aoukili* - rejet du recours de la partie nommée.

2. L'actuelle solution législative (rappel détaillé)

► Ainsi que cela a été dit au début de cette partie du cours, elle résulte de la loi **n° 2004-228 du 15 mars 2004** *encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*.

➢ L'article premier de la loi du 15 mars 2004 dispose :

« **Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.**

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »

► Quel est donc l'apport de cette loi ?

➢ L'ancienne jurisprudence interdisait, notamment, le port *ostentatoire* de signes d'appartenance religieuse.

➢ La loi du 15 mars 2004 met un terme à cette jurisprudence, et interdit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent *ostensiblement* une appartenance religieuse ».

À première vue, l'apport de la loi n'est pas considérable : *ostensiblement* a été substitué à *ostentatoire.*

Sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, le mot *ostentatoire* faisait l'objet d'interprétations divergentes.

Avec la loi du 15 mars 2004, il risque d'en être de même du mot *ostensiblement*.

Voilà pourquoi le ministre de l'Éducation nationale a publié, après deux échecs, une circulaire destinée à guider les enseignants et les chefs d'établissement dans l'application de la nouvelle loi.

En partie négociée avec les organisations syndicales, **la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004** (JO du 22-5-2004) apporte les précisions interprétatives suivantes :

a - Champ d'application de la loi : La loi s'applique aux écoles, aux collèges et aux lycées publics ;

b - Les signes interdits : Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive.

La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.

Elle n'interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu'il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l'établissement ;

c - Conséquences de la violation de la loi par un élève : Lorsqu'un élève inscrit dans l'établissement se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l'interdiction, il importe d'engager immédiatement le dialogue avec lui. […]

Le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir que la procédure disciplinaire n'est utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l'élève de se conformer à la loi.

Si le conseil de discipline prononce une décision d'exclusion de l'élève, il appartiendra à l'autorité académique d'examiner avec l'élève et ses parents les conditions dans lesquelles l'élève poursuivra sa scolarité ;

d - Les personnes non concernées : La loi ne concerne pas les parents d'élèves. Elle ne s'applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l'enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d'organisation de l'examen qui visent notamment à garantir le respect de l'ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l'identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes.

Comme on le voit, **le point b ci-dessus** n'est pas d'une clarté… biblique. Il repose sur une certaine subjectivité et peut donc entraîner des divergences d'interprétation.

Par une décision du 8 octobre 2004, le Conseil d'État a rejeté la requête formée contre cette circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Il a en effet jugé

i. que le ministre avait pu légalement rappeler que la loi du 15 mars 2004 interdisait, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse (exemples de tels signes ou tenues : le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive),

ii. et que ladite circulaire ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, telle notamment qu'elle est garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics – CE, 8 octobre 2004, *Union française pour la cohésion nationale*, n° 269077.

[/FIN]

/

ANNEXES (schémas)

Ce qu'il faut entendre par « Personnes publiques »

Personnes publiques

(raccourci pour désigner les *personnes morales de droit public*, autrement dit les **personnes morales** globalement soumises au droit public)

L'État

Les personnes publiques à compétence spéciale

- les établissements publics : universités…
- les groupements d'intérêt public
- la Banque de France (personne publique à part)

Les collectivités territoriales

- les communes
- les départements
- les régions…

Ce qu'il faut entendre par « Personnes privées »

Personnes privées

Autrement dit personnes globalement soumises au droit privé

Personnes physiques

Vous, votre voisin…

Personnes morales de droit privé appartenant à des particuliers

Entreprises privées ou sociétés privées

Personnes morales de droit privé appartenant à des personnes morales de droit public

Entreprises publiques…
Exemple : **E.D.F.** (Société Anonyme à Conseil d'administration depuis la loi du 9 août 2004) « appartient » à l'État (83,7% du capital).

À quoi reconnaît-on un service public ? (Critère 1 + critère 2)

2e critère : Lien avec une personne publique (a et b)

a - Lien direct avec une personne publique (2 cas)

1er critère

1er cas

PERSONNE PUBLIQUE responsable (État, commune, etc.) —gère **(régie ou autre)**→ Activité d'intérêt général

2e cas

PERSONNE PUBLIQUE responsable (État, commune, etc.) —contrat→ **Autre PERSONNE PUBLIQUE** (État, commune, etc.) —gère→ Activité d'intérêt général

Activité d'intérêt général = **SERVICE PUBLIC**

- Service public administratif
- Service public industriel et commercial

b - Lien indirect avec une personne publique

PERSONNE PUBLIQUE responsable (État, commune, etc.) —*Habilite* et *contrôle*→ **PERSONNE PRIVÉE** (Société, association, entreprise…) —*gère*→ Activité d'intérêt général

Propriété
ou
Autorisation unilatérale
ou
Contrat d'habilitation à gérer un service public

Activité d'intérêt général = **SERVICE PUBLIC**

- Service public administratif
- Service public industriel et commercial

Contrat de **concession** ou de **délégation de service public**

Rémunération du cocontractant **liée** à l'exploitation du service public.
Transfert du risque d'exploitation au cocontractant.

Marché de service public

Rémunération du cocontractant **non liée** à l'exploitation du service public.
Pas de transfert du **risque** d'exploitation au cocontractant.

L'habilitation à gérer un service public (ou gestion déléguée au sens large)[1]

Propriété
La personne privée est une société dont le capital est, au moins, majoritairement public.

Habilitation contractuelle
Autorisation de gérer le service public fondée sur un contrat.

Habilitation unilatérale
Autorisation de gérer le service public fondée sur un acte administratif unilatéral.

Contrats de concession
Rémunération du cocontractant **liée** aux résultats de l'exploitation du service public et transfert de risque

Marchés de service public
Rémunération du cocontractant **non liée** aux résultats de l'exploitation du service public et **pas** de transfert de risque

Contrat de concession de service public
Expression désignant les contrats d'habilitation à gérer un service public conclus par des personnes publiques autres que les collectivités territoriales.

Contrat de délégation de service public
Expression désignant les contrats de concession de service public conclus par des collectivités territoriales (Communes, départements, régions…)

Contrat de gérance
(Exemple)
Rémunéré forfaitairement par la personne publique, le gérant n'est point autonome.

[1] Deux remarques d'ordre général :
- si le service public est géré par la personne publique dont il relève, on parle de gestion en régie ;
- la gestion déléguée peut être effectuée aussi bien par une personne privée que par une autre personne publique.